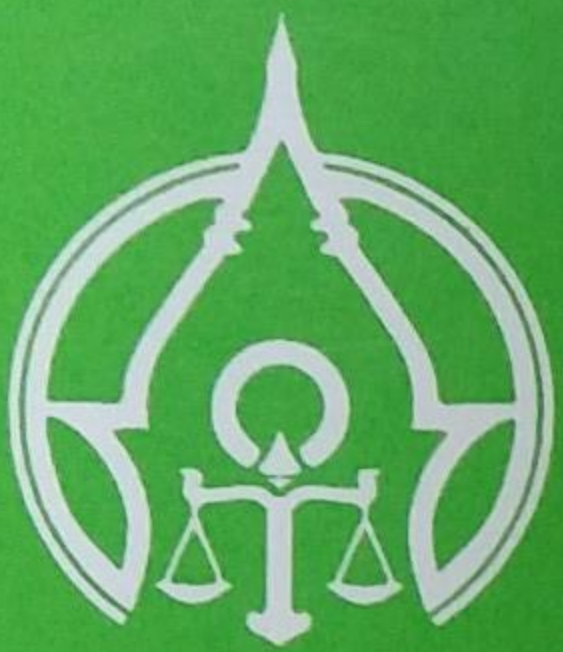


วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
ธันวาคม 2556

✧ บทความทั่วไป

- อายุความการใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืน
- ความสับสนของการใช้คำในกฎหมาย :
“การเลิกสัญญา” “ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญา”
- หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันกับองค์ความรู้ดั้งเดิม
- ประเด็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา :
ศึกษากรณีรูปร่าง รูปทรง สี และกลิ่น
- ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ : ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- ศาลอาญาระหว่างประเทศ
- Customer Due Dilligence Measures under Money Laundering
Regulations 2007 of the United Kingdom
- ข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นความลับจริงหรือไม่?

✧ แนะนำกฎหมายใหม่

✧ คำพิพากษากฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

✧ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ

ชุดวิชา



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ อิงครัต ดลเจิม

คำถาม

นางสร้อยต้องการจ้าง นายจ้อย มาเป็นคนขับรถ แต่เวลาแสดงเจตนาเข้าใจว่า นายเล็ก คือ นายจ้อย จึงได้แสดงเจตนาทำนิติกรรมจ้างนายเล็ก ดังนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า การแสดงเจตนาทำนิติกรรมจ้างนายเล็กของนางสร้อยดังกล่าว มีผลเป็นอย่างไร อธิบาย

หลักกฎหมาย

ปพพ. มาตรา 154 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงเจตนาจะมีได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตาม หาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนาอันเป็นโมฆะไม่ เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงนั้น”

วินิจฉัย

ป.พ.พ. มาตรา 156 บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ

ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม และความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น” (8 คะแนน)

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม ตาม ปพพ. มาตรา 156 ในกรณี ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม ซึ่งหมายถึง ผู้แสดงเจตนาได้ตั้งใจจะแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับบุคคลหนึ่ง แต่เวลาแสดงเจตนาออกมากลับไปแสดงเจตนาทำนิติกรรมกับบุคคลอีกคนหนึ่ง โดยเข้าใจผิดว่า เป็นคนๆ เดียวกับคนที่ตั้งใจจะทำนิติกรรมนั้นด้วย

กรณีความสำคัญผิดในตัวบุคคล ที่จะทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะนั้นตัวบุคคลนั้นจะต้องเป็นสาระสำคัญด้วย หากตัวบุคคลนั้นมีใช้สาระสำคัญแล้ว แม้จะมีความสำคัญผิดในตัวบุคคลก็ไม่ได้ทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ เช่น การขายของเบ็ดเตล็ด ใครจะมาเป็นผู้ซื้อนั้นมีใช้สาระสำคัญ ดังนั้นแม้ผู้ขายจะสำคัญผิดว่านายเขียวเป็นนายขาว ก็ไม่เป็นผลให้นิติกรรมการขายที่ผู้ขายขายให้กับนายเขียว ต้องตกเป็นโมฆะไป

สำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ถือตัวบุคคลเป็นสาระสำคัญ ได้แก่ สัญญาให้ สัญญายืม สัญญาเช่า ทรัพย์ สัญญาแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาตัวแทน เป็นต้น ฉะนั้น นิติกรรมสัญญาเหล่านั้น หากมีการแสดงเจตนาโดยความสำคัญผิดในตัวบุคคล นิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ

นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยในข้อนี้ผิดพลาดโดยวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินตาม ปพพ. มาตรา 157 ซึ่งการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน นั้นมีความแตกต่างกับการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม (มาตรา 156) ตามตารางดังนี้

การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม	การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน
1. มาตรา 156 2. มีผลเป็น “โมฆะ” 3. เป็นส่วนที่ต้องอยู่ตามสภาพของนิติกรรม คือ ลักษณะของนิติกรรม บุคคลที่ทำนิติกรรมและทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรม ซึ่งมีอยู่ในนิติกรรมอยู่แล้ว 4. ผลต่อบุคคลภายนอกอยู่ในบังคับของเรื่อง ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ดังนั้นบุคคลภายนอกได้อะไรมาก็ต้องคืนแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้แสดงเจตนาโดยสำคัญผิดนั้น	1. มาตรา 157 2. มีผลเป็น “โมฆียะ” 3. เป็นเรื่องเจตนาของแต่ละบุคคล ซึ่งมักคิดตามแต่ตนจะต้องการว่าคุณสมบัติอย่างไรจึงจะถือเป็นสาระสำคัญ 4. ผลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 1329 กล่าวคือ ถ้าบุคคลภายนอกได้ทรัพย์สินใดมาโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทนแล้ว บุคคลภายนอกผู้นั้นย่อมไม่เสียสิทธิในทรัพย์สินที่ได้มานั้นแต่ประการใด



กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

รองศาสตราจารย์วรวิทย์ เทพทอง¹

คำถาม นายปลิวให้นายสายยืมข้าวสารไป 5 กระสอบ เพื่อนำไปเลี้ยงในการได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยทำสัญญากำหนดคืนกันอีก 6 เดือน ก่อนครบ 6 เดือน นายสายเตรียมข้าวสารที่จะส่งคืนไว้ในโกดังของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า คืนวันหนึ่งมีคนร้ายขโมยข้าวสารในโกดังนั้นไปทั้งหมด เพราะช่วงเวลานั้นข้าวสารในท้องตลาดมีราคาดี ต่อมาครบกำหนด 6 เดือน ที่ต้องส่งมอบข้าวสารคืนตามสัญญา นายสายไม่สามารถกระทำได้ประกอบกับขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่วนนายปลิวอยู่ต่างประเทศยังไม่ได้ติดต่อกับนายสายแต่อย่างใด

ให้วินิจฉัยว่า นายสายตกเป็นผู้ผิดนัดหรือไม่ และต้องชดใช้ค่าสินทดแทนให้แก่นายปลิวหรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ ยกหลักกฎหมายตามป.พ.พ.มาตรา 204 (5 คะแนน) มาตรา 205 (2 คะแนน) และมาตรา 215 (3 คะแนน)

วินิจฉัย ตามปัญหา นายปลิวให้นายสายยืมข้าวสารไป 5 กระสอบ เพื่อนำไปเลี้ยงในการได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยทำสัญญากำหนดคืนกันอีก 6 เดือน เช่นนี้เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระกันตามวันแห่งปฏิทิน ตามป.พ.พ.มาตรา 204 วรรคสอง (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๕๕/๒๕๕๔) ต่อมาครบกำหนด 6 เดือน ที่ต้องส่งมอบข้าวสารคืนตามสัญญา นายสายไม่สามารถชำระหนี้ด้วยการส่งมอบข้าวสารจำนวน 5 กระสอบได้ แม้นายปลิวอยู่ต่างประเทศยังไม่ได้ติดต่อกับนายสายแต่อย่างใดก็ตาม เพราะกรณีดังกล่าวนายสายตกเป็นผู้ผิดนัดโดยนายปลิวเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนเลย ตามป.พ.พ.มาตรา 204 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว” (5 คะแนน) แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่านายสายเตรียมข้าวสารที่จะส่งคืนไว้ในโกดังของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า คืนวันหนึ่งมีคนร้ายขโมยข้าวสารในโกดังนั้นไปทั้งหมด เพราะช่วงเวลานั้นข้าวสารในท้องตลาดมีราคาดีนั้น ไม่อาจนำมาอ้างว่ายังไม่ผิดนัดได้ ทั้งมิใช่กรณีเป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้ตามป.พ.พ.มาตรา 205 ที่บัญญัติไว้ว่า “ตราบใดการชำระหนี้้นยังมิได้กระทำลงเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่”

¹ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์, กรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายแพ่ง 2

เพราะกรณีดังกล่าวยังอยู่ในวิสัยที่สามารถหาข้าวสารจำนวน 5 กระสอบมาชำระหนี้ให้แก่นายปลิวได้ (2 คะแนน)

ดังนั้นนายสายต้องชดใช้ค่าสินทดแทนให้แก่นายปลิว ตามป.พ.พ. มาตรา 215 ที่บัญญัติว่า “เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ไซ้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้” (3 คะแนน)

สรุป นายสายตกเป็นผู้ผิดนัด และต้องชดใช้ค่าสินทดแทนให้แก่นายปลิว

วิเคราะห์คำถาม

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการผิดนัดและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ประเด็นที่นักศึกษาต้องวินิจฉัยคือ นายสายตกเป็นผู้ผิดนัดหรือไม่ และนายสายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ปลิวหรือไม่

ประเด็นแรก การผิดนัดของลูกหนี้นั้นมี 2 กรณี คือ 1. ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ต้องเตือน ตามป.พ.พ.มาตรา 204 วรรคหนึ่ง และ 2. ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน ตามป.พ.พ.มาตรา 204 วรรคสอง กรณีตามคำถามเป็นหนี้ที่มีกำหนดชำระตามวันแห่งปฏิทิน การกำหนดชำระหนี้โดยระบุเป็นจำนวนวัน เดือน หรือปี นั้นถือได้ว่าเป็นไปตามปฏิทิน ซึ่งเมื่อถึงกำหนดตามปฏิทินนั้นแล้ว ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ลูกหนี้อย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดในวันรุ่งขึ้นโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องให้คำเตือนแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายปลิวให้นายสายยืมข้าวสารไป 5 กระสอบ เพื่อนำไปเลี้ยงในการได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยทำสัญญากำหนดคืนกันอีก 6 เดือน ต่อมาครบกำหนด 6 เดือน ที่ต้องส่งมอบข้าวสารคืนตามสัญญา นายสายไม่สามารถกระทำได้ เช่นนี้ นายสายย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดโดยนายปลิวไม่ต้องเตือน ตามป.พ.พ.มาตรา 204 วรรคสอง

การที่นายสายเตรียมข้าวสารที่จะส่งคืนไว้ในโกดังของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า คืบวันหนึ่งมีคนร้ายขโมยข้าวสารในโกดังนั้นไปทั้งหมด เพราะช่วงเวลานั้นข้าวสารในท้องตลาดมีราคาดีนั้น ไม่อาจนำมาอ้างว่ายังไม่ผิดนัดได้ ทั้งมิใช่กรณีเป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้ตามป.พ.พ.มาตรา 205 ที่บัญญัติไว้ว่า “ตราบใดการชำระหนี้หนี้ยังมีได้กระทำการเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่” เพราะกรณีดังกล่าวยังอยู่ในวิสัยที่สามารถหาข้าวสารจำนวน 5 กระสอบมาชำระหนี้ให้แก่นายปลิวได้

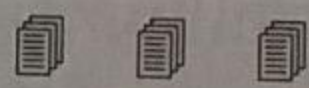
ประเด็นที่สอง เมื่อวินิจฉัยแล้วว่า นายสายตกเป็นผู้ผิดนัดและไม่ชำระหนี้ด้วยการส่งมอบข้าวสารจำนวน 5 กระสอบตามสัญญาได้ จึงเป็นกรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ไซ้ นายปลิวเจ้าหนี้อย่อมมีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นได้ ตามป.พ.พ.มาตรา 205 การที่ข้าวสารที่นายสายเตรียมจะส่งคืนไว้ในโกดังถูกคนร้ายขโมยไปทั้งหมดนั้นก็มิใช่กรณีการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะข้าวสารจำนวน 5 กระสอบนั้นมีใช้ทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง นายสายสามารถเอาข้าวสารจำนวน 5 กระสอบจากที่อื่นมาชำระหนี้ให้แก่นายปลิวได้ ทั้งไม่ปรากฏว่าไม่มีข้าวสารดังกล่าวที่นายสายจะหามาชำระหนี้ได้แต่อย่างใด

จากคำถามข้อนี้ นักศึกษาต้องอ่านคำถามให้ละเอียดและจับประเด็นให้ได้ว่า ให้วินิจฉัยประเด็นใด

ซึ่งในข้อนี้มี 2 ประเด็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

นักศึกษาหลายคนวินิจฉัยผิดไปว่านายสายยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด เพราะนายปลิวเจ้าหนี้ยังมีได้ให้คำเตือนโดยหลงไปปรับบทตามป.พ.พ.มาตรา 204 วรรคหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน นักศึกษาบางคนไปวินิจฉัยว่าเป็นการชำระหนี้ที่กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะไปเอาข้อเท็จจริงที่ว่านายสายเตรียมข้าวสารที่จะส่งคืนไว้ในโกดังของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า คืบวันหนึ่งมีคนร้ายขโมยข้าวสารในโกดังนั้นไปทั้งหมด โดยเห็นว่าการที่คนร้ายขโมยข้าวสารไปไม่ได้เกิดจากพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ ตามป.พ.พ.มาตรา 219 จึงสรุปว่านายสายลูกหนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี้และไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายปลิว โดยอาจหลงลืมไปว่าข้าวสารที่นายสายยืมไปเลี้ยงในการได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีใช้ทรัพย์สินเฉพาะสิ่งซึ่งสามารถหาข้าวสารอื่น 5 กระสอบที่เป็นชนิดและประเภทที่ยืมไปนั้นมาคืนนายปลิวได้ และมีนักศึกษาบางคนวินิจฉัยประเด็นที่นายสายตกเป็นผู้ผิดนัดถูกแล้ว แต่ไปพลาดประเด็นค่าสินไหมทดแทน โดยไปวินิจฉัยถึงมาตรา 217 ที่บัญญัติว่า “ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างเวลาที่ตนผิดนัด ทั้งจะต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วย เว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลากำหนดก็จะต้องเกิดมียุ่่นเอง” ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดดังที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ให้ทราบแล้วว่า กรณีนี้มีได้เป็นเรื่องการชำระหนี้พ้นวิสัยจึงไม่อาจนำมาตรา 217 มาปรับวินิจฉัยได้

สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชานี้ อาจารย์ขอเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาเพื่อสู้ต่อไป อย่าท้อแท้ให้ยึดหลักว่า “ยิ่งตกยิ่งแน่น ได้กำไรมากกว่าคนอื่นในการทำความเข้าใจ” และพยายามอ่านเอกสารการสอนให้เข้าใจครบทั้ง 15 หน่วย เนื่องจากกฎหมายลักษณะหนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมด 1755 มาตรา เป็นเรื่องที่ยากที่สุด (ความเห็นอาจารย์) ฉะนั้น ขอให้นักศึกษาหมั่นฝึกฝนทบทวนทำความเข้าใจด้วยทฤษฎีและอ่านคำอธิบายประกอบกับฝึกฝนการเขียนตอบข้อสอบอัตโนมัติโดยนำข้อสอบเก่าจากที่มีการวิเคราะห์ข้อสอบในวารสารหลาย ๆ ฉบับมาประกอบการศึกษาทำความเข้าใจและหมั่นฝึกเขียนหลายๆ ครั้งในข้อเดิมเพื่อให้เกิดทักษะจนสามารถจัดวางลำดับการวินิจฉัยให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนครบถ้วนทุกประเด็น ก็คงจะช่วยนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง





กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก

รองศาสตราจารย์วรุฒิ เทพทอง¹

คำถามที่ 1. นายก้อนฟ้าหมั้นกับนางสาวน้ำฝนด้วยแหวนเพชรวงหนึ่งเป็นของหมั้น ในระหว่างพิธีหมั้น นายแรงกล้าเพื่อนชายของนายก้อนฟ้ามีความพึงใจนางสาวน้ำฝนมาก จนทั้งคู่แอบลักลอบได้เสียกัน ต่อมา นายก้อนฟ้าทราบเรื่องจึงถอนหมั้นกับนางสาวน้ำฝนพร้อมทั้งเรียกให้นางสาวน้ำฝนคืนแหวนเพชรของหมั้น และเรียกค่าทดแทนจากนายแรงกล้า ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสาวน้ำฝนมีความประสงค์จะสมรสกับนายก้อนฟ้า เมื่อนายก้อนฟ้าปฏิเสธการสมรส นางสาวน้ำฝนจึงอ้างว่านายก้อนฟ้าผิดสัญญาหมั้นกับตน

ให้วินิจฉัยว่า นายก้อนฟ้าจะเรียกให้นางสาวน้ำฝนคืนแหวนเพชรของหมั้น และเรียกค่าทดแทนจากนายแรงกล้าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

รศ.คำตอบ ยกหลักกฎหมายตามป.พ.พ.มาตรา 1439 (1 คະแนน) มาตรา 1442 (4 คະแนน) และ มาตรา 1445 (5 คະแนน)

วินิจฉัย ตามปัญหานายก้อนฟ้าหมั้นกับนางสาวน้ำฝนด้วยแหวนเพชรวงหนึ่งเป็นของหมั้น ในระหว่างพิธีหมั้นนายแรงกล้าเพื่อนชายของนายก้อนฟ้ามีความพึงใจนางสาวน้ำฝนมาก จนทั้งคู่แอบลักลอบได้เสียกัน เช่นนี้การกระทำของนางสาวน้ำฝนเป็นกรณีที่มีเหตุสำคัญที่ทำให้นายก้อนฟ้าไม่สมควรสมรสด้วย การที่นายก้อนฟ้าปฏิเสธไม่ยอมสมรสกับนางสาวน้ำฝนจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาหมั้นตามป.พ.พ.มาตรา 1442 ที่บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่หมั้นทำให้ชายไม่สมควรสมรสกับหญิงนั้น ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้และให้หญิงคืนของหมั้นแก่ชาย” เมื่อนายก้อนฟ้าถอนหมั้นกับนางสาวน้ำฝน จึงมิได้เป็นการผิดสัญญาหมั้นตามป.พ.พ.มาตรา 1439 ที่บัญญัติว่า “เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดชอบค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย” แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะปรากฏว่าสาวน้ำฝนมีความประสงค์จะสมรสกับนายก้อนฟ้าก็ตาม และเมื่อนายก้อนฟ้าเรียกให้นางสาวน้ำฝนคืนแหวนเพชรของหมั้น ดังนั้น นางสาวน้ำฝนจึงต้องคืนแหวนเพชรที่เป็นของหมั้นให้แก่นายก้อนฟ้า ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1442 (5 คະแนน)

สำหรับกรณีที่นายก้อนฟ้าเรียกค่าทดแทนจากนายแรงกล้านั้น ป.พ.พ. มาตรา 1445 บัญญัติว่า “ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้นเมื่อได้บอกเลิกสัญญาหมั้นแล้วตามมาตรา 1442 หรือมาตรา 1443 แล้วแต่กรณี” ดังนั้นแล้ว นายก้อนฟ้าจึงเรียก

¹ ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3

คำทดแทนจากนายแรงกล้าผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับนางสาวน้ำฝนคู่หมั้นของนายกองฟ้าโดยรู้ถึงการหมั้นระหว่างนางสาวน้ำฝนกับนายกองฟ้าแล้วได้ (5 คะแนน)

สรุป นายกองฟ้าเรียกให้นางสาวน้ำฝนคืนแหวนเพชรของหมั้นได้ และเรียกคำทดแทนจากนายแรงกล้าได้

วิเคราะห์คำถามที่ 1

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการหมั้น ข้อเท็จจริงในคำถามได้บอกแล้วว่านายกองฟ้าหมั้นกับนางสาวน้ำฝนด้วยแหวนเพชรวงหนึ่งเป็นของหมั้น ดังนั้นประเด็นสัญญาหมั้นเกิดหรือไม่นั้น นักศึกษาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีกประเด็นที่นักศึกษาต้องวินิจฉัยคือ การที่นายกองฟ้าปฏิเสธการสมรสนั้นเป็นการผิดสัญญาหมั้นหรือบอกเลิกสัญญาหมั้น เพราะผลทางกฎหมายเกี่ยวกับของหมั้นนั้นแตกต่างกัน เห็นได้ว่าที่นายกองฟ้าปฏิเสธการสมรสกับนางสาวน้ำฝนนั้น สาเหตุมาจากนางสาวน้ำฝนลักลอบได้เสียกับนายแรงกล้าเพื่อนชายของนายกองฟ้า ย่อมเป็นเหตุสำคัญที่นายกองฟ้าไม่สมควรสมรสกับนางสาวน้ำฝน ดังนั้น การปฏิเสธการสมรสดังกล่าวจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาหมั้น ตามป.พ.พ.มาตรา 1442 เมื่อเป็นการบอกเลิกสัญญาหมั้นจึงมิใช่การผิดสัญญาหมั้น แม้นางสาวน้ำฝนจะยังมีความประสงค์จะสมรสกับนายกองฟ้าอยู่ก็ตาม นางสาวน้ำฝนจะอ้างว่านายกองฟ้าผิดสัญญาหมั้นกับตนย่อมไม่ได้ ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับของหมั้น คือ ป.พ.พ.มาตรา 1442 ที่บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่หมั้นทำให้ชายไม่สมควรสมรสกับหญิงนั้น ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้และให้หญิงคืนของหมั้นแก่ชาย” ดังนั้นป.พ.พ.มาตรา 1442 ที่บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่หมั้นทำให้ชายไม่สมควรสมรสกับหญิงนั้น ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้และให้หญิงคืนของหมั้นแก่ชาย” จึงต้องคืนของหมั้นคือแหวนเพชรวงนั้นแก่นายกองฟ้า

ประเด็นต่อมา คือนายกองฟ้าจะเรียกคำทดแทนจากนายและเรียกคำทดแทนจากนายแรงกล้าเพื่อนของตนได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายแรงกล้าเพื่อนของนายกองฟ้าได้ร่วมประเวณีกับนางสาวน้ำฝนโดยรู้ถึงการหมั้นระหว่างนายกองฟ้ากับนางสาวน้ำฝน และเมื่อนายกองฟ้าได้บอกเลิกสัญญาหมั้นกับนางสาวน้ำฝนแล้ว นายกองฟ้าย่อมมีสิทธิเรียกคำทดแทนจากนายแรงกล้าได้ ตามป.พ.พ. มาตรา 1445 ที่บัญญัติว่า “ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียกคำทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้น เมื่อได้บอกเลิกสัญญาหมั้นแล้วตามมาตรา 1442 หรือมาตรา 1443 แล้วแต่กรณี”

จากคำถามข้อนี้ นักศึกษาต้องอ่านคำถามให้ละเอียดและจับประเด็นให้ได้ว่า ให้วินิจฉัยประเด็นใด ซึ่งในข้อนี้มี 2 ประเด็นคือ 1. นายกองฟ้าจะเรียกให้นางสาวน้ำฝนคืนแหวนเพชรของหมั้นได้หรือไม่ และ 2. นายกองฟ้าเรียกคำทดแทนจากนายแรงกล้าได้หรือไม่

นักศึกษาหลายคนวินิจฉัยผิดไปว่านายกองฟ้าผิดสัญญาหมั้นโดยไม่ยอมสมรสกับนางสาวน้ำฝน ทั้งที่สาวน้ำฝนมีความประสงค์จะสมรสกับนายกองฟ้า ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาดไม่มีหลักกฎหมายมาปรับกับ

การวินิจฉัย และหลายคนวินิจฉัยถึงการเรียกค่าทดแทนจากนางสาวน้ำฝนซึ่งคำถามมิได้ประสงค์ให้วินิจฉัยแต่อย่างใด จึงทำให้ไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ นอกจากนั้นในการถามเรื่องค่าทดแทนที่เรียกจากนายแรงกล้า นั้น มิได้ถามว่าเรียกค่าทดแทนอะไรได้บ้าง นักศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยไปถึงซึ่งหลายคนพยายามที่จะระบค่าทดแทนต่างๆ ซึ่งในคำถามมิได้ให้มาเพราะไม่ประสงค์ให้วินิจฉัยไปถึงประเด็นนั้น เพียงแต่นักศึกษาตอบว่านายก่อฟ้าเรียกค่าทดแทนจากนายแรงกล้าได้ ก็ได้คะแนนในส่วนนี้แล้ว

คำถามที่ 2. นายจอมใจบุตรนายวินสมรสกับนางเย็นมีบุตรด้วยกัน 1 คน คือนายตาล นายจอมใจมีนางร่อนเป็นภริยาน้อยและมีบุตร 1 คน คือเด็กชายน้ำ นายจอมใจส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายน้ำมาโดยตลอด ต่อมานายจอมใจป่วยด้วยโรคร้าย ทำพินัยกรรมแบบธรรมดาตายยกเงินสดจำนวน 400,000 บาทให้เด็กชายน้ำ โดยนายจอมใจลงลายมือชื่อในพินัยกรรมต่อหน้านางร่อนและแพทย์ผู้รักษา โดยนางร่อนและแพทย์ผู้รักษาลงชื่อเป็นพยานไว้ในพินัยกรรมนั้นด้วย ต่อมานายจอมใจถึงแก่ความตาย มีทรัพย์สินมรดกทั้งหมดได้แก่รถยนต์ ปีน และเงินสดอีกจำนวน 500,000 บาท

ให้วินิจฉัยว่า มรดกของนายจอมใจตกทอดให้แก่ใคร เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ ยกหลักกฎหมายตามป.พ.พ. มาตรา 1627 (1 คะแนน) มาตรา 1629 (1) (2) (2 คะแนน) และวรรคท้าย มาตรา 1630 (1 คะแนน) วรรคหนึ่ง มาตรา 1635 (1) (2 คะแนน) มาตรา 1653 วรรคหนึ่ง (2 คะแนน) และมาตรา 1656 (2 คะแนน)

วินิจฉัย ตามปัญหานายจอมใจเจ้ามรดกทำพินัยกรรมแบบธรรมดาตายยกเงินสดจำนวน 400,000 บาทให้เด็กชายน้ำ โดยนางร่อนและแพทย์ผู้รักษาลงชื่อเป็นพยานไว้ในพินัยกรรมนั้น เช่นนี้พินัยกรรมแบบธรรมดามีผลสมบูรณ์ ตามป.พ.พ.มาตรา 1656 นางร่อนไม่มีสิทธิรับมรดกอันเป็นมรดกตามพินัยกรรมนั้น เพราะเป็นพยานในพินัยกรรม ตามป.พ.พ.มาตรา 1653 วรรคหนึ่ง ส่วนเด็กชายน้ำมีสิทธิรับเงินสดจำนวน 400,000 บาท ในฐานะผู้รับพินัยกรรม (5 คะแนน)

นายจอมใจมีทรัพย์สินที่ได้จำหน่ายโดยพินัยกรรมคือ ปีนและเงินสดอีกจำนวน 100,000 บาท และส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับอีกคือรถยนต์ ทรัพย์สินส่วนนี้ย่อมตกให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของนายจอมใจ ซึ่งนายจอมใจมีทายาทโดยธรรมได้แก่ นายวินบิดา นางเย็นคู่สมรส นายตาล และเด็กชายน้ำผู้สืบสันดาน ตามป.พ.พ.มาตรา 1627 มาตรา 1629 (1) (2) และวรรคท้าย ดังนั้น ทรัพย์สินมรดกในส่วนนี้จึงตกให้แก่ นายวิน นางเย็น นายตาล และเด็กชายน้ำ คนละส่วนเท่าๆกัน ตามป.พ.พ.มาตรา 1630 วรรคหนึ่ง และมาตรา 1635 (1) (5 คะแนน)

สรุป มรดกของนายจอมใจ ได้แก่รถยนต์ ปีน และเงินสดทั้งหมดจำนวน 500,000 บาท ตกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ คือ

1. เงินสดจำนวน 500,000 บาท ตกให้แก่เด็กชายน้ำในฐานะผู้รับพินัยกรรมจำนวน 400,000 บาท และเงินจำนวน 100,000 บาท ตกให้แก่ นายวินบิดา นางเย็นคู่สมรส นายตาล และเด็กชายน้ำ ในฐานะทายาท

โดยธรรมคนละ 25,000 บาท

2. รถยนต์ ปีน ตกได้แก่นายวินบิดา นางเย็นคู่สมรส นายตาล และเด็กชายน้ำ ในฐานะทายาทโดยธรรม คนละส่วนเท่าๆ กัน

วิเคราะห์คำถามที่ 2

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการแบ่งมรดกซึ่งมีพินัยกรรม ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือ พินัยกรรมสมบูรณ์หรือไม่ ข้อกำหนดในพินัยกรรมใช้บังคับได้หรือไม่ และทรัพย์สินนอกพินัยกรรมและทรัพย์สินที่ไม่มีผลบังคับได้ตามพินัยกรรมตกได้แก่ใคร

ประเด็นแรก พินัยกรรมสมบูรณ์หรือไม่นั้น พินัยกรรมมี 5 แบบ ตามคำถามเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายจอมใจผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้นต่อหน้าพยานคือนางร้อนและแพทย์ผู้รักษาทั้งสองคนพร้อมกัน พินัยกรรมดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ ทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมย่อมตกไปตามข้อกำหนดในพินัยกรรมนั้น

ประเด็นที่สอง ข้อกำหนดในพินัยกรรมที่ยกรถยนต์ให้นางร้อนใช้บังคับไม่ได้ เพราะนางร้อนเป็นพยานในพินัยกรรม ไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรม ตามป.พ.พ.มาตรา 1653 วรรคหนึ่ง รถยนต์ดังกล่าวจึงต้องตกได้แก่ทายาทโดยธรรมของนายจอมใจต่อไป ส่วนเด็กชายน้ำมีสิทธิรับเงินสดจำนวน 400,000 บาท ในฐานะผู้รับพินัยกรรม

ประเด็นที่สาม ทรัพย์สินนอกพินัยกรรมได้แก่ ปีน และเงินสดอีกจำนวน 400,000 บาท และรถยนต์ซึ่งไม่มีผลบังคับตามพินัยกรรม ย่อมตกได้แก่ทายาทโดยธรรม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1620 วรรคสอง ทายาทโดยธรรมของนายจอมใจ ได้แก่ นายวิน บิดา นางเย็น คู่สมรส นายตาล บุตรชอบด้วยกฎหมาย และเด็กชายน้ำ บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง คนละส่วนเท่าๆกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1627 มาตรา 1629 (1) (2) และวรรคท้าย มาตรา 1630 และมาตรา 1635 (1)

นักศึกษาต้องอ่านคำถามให้ละเอียดและจับประเด็นให้ได้ก่อนลงมือวินิจฉัย เนื่องจากข้อสอบมรดกจะมีหลายประเด็นมีความละเอียดโดยธรรมชาติของเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว และทุกครั้งข้อสอบก็มักจะให้นักศึกษาวินิจฉัยถึงแบบของพินัยกรรมและการแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมเป็นหลัก จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้างในระภาคการศึกษา

จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อนักศึกษาวินิจฉัยผิดพลาดแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

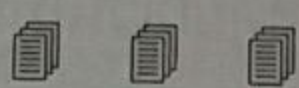
1. วินิจฉัยว่า พินัยกรรมเป็นโมฆะ เพราะผู้รับพินัยกรรมเป็นพยานในพินัยกรรมด้วย ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาด ตามคำถามพินัยกรรมสมบูรณ์ตามแบบธรรมดา เฉพาะข้อกำหนดในพินัยกรรมที่ยกทรัพย์สิน

มรดกให้นางร่อนซึ่งเป็นพยานในพินัยกรรมเท่านั้นที่ใช้บังคับไม่ได้ หากได้เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะไปทั้งฉบับไม่

2. วินิจฉัยถึงการตกทอดแห่งทรัพย์นอกพินัยกรรมและทรัพย์ที่ไม่อาจบังคับได้ตามพินัยกรรม ไม่ครบถ้วน เช่น วินิจฉัยว่าตกได้แก่ นางเย็น คู่สมรส นายตาล บุตรชอบด้วยกฎหมาย และเด็กชายน้ำ บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง คนละส่วนเท่าๆกัน โดยลืมนิิจฉัยถึงนายวิน บิดา หรือนักศึกษาบางคนลืมนิิจฉัยถึงนายตาล บุตรชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านชุดวิชานี้ อาจารย์ขอเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาเพื่อสู้ต่อไป อย่าท้อแท้ และพยายามอ่านเอกสารการสอนให้เข้าใจครบทั้ง 15 หน่วย หมั่นฝึกฝนการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยโดยนำข้อสอบเก่าจากที่อาจารย์วิเคราะห์ข้อสอบในวารสารหลาย ๆ ฉบับมาอ่านศึกษาทำความเข้าใจ จะทำให้รู้ถึงลำดับความคิดในการสร้างโครงสร้างการตอบข้อสอบอัตนัยก่อนที่จะลงมือเขียนคำตอบและหมั่นฝึกเขียนหลายๆครั้งในข้อเดิมเพื่อให้เกิดทักษะจนสามารถจัดวางลำดับการวินิจฉัยให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนครบถ้วนทุกประเด็น

ในส่วนข้อสอบอัตนัยทั้ง 3 ข้อนั้น โดยปกติจะเป็นเรื่องการหมั้นและหรือการสมรส 1 ข้อ บิดามารดากับบุตร หรือบุตรบุญธรรม 1 ข้อ และมรดกกับพินัยกรรมอีก 1 ข้อ นักศึกษาอาจสงสัยว่าทำไมแต่ละข้อจึงใช้ตัวบทหลายมาตรา โดยเฉพาะเรื่องมรดกกับพินัยกรรม ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าโดยธรรมชาติของชุดวิชานี้ ตัวบทบัญญัติแต่ละมาตราจะมีความสัมพันธ์กันมากหลายมาตรา โดยเฉพาะเรื่องมรดกกับพินัยกรรมนั้น นักศึกษาต้องยกมาตราที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถาม อาทิ แบบของพินัยกรรม ข้อกำหนดในพินัยกรรม พยาน ผู้เขียนพินัยกรรม และในกรณีทรัพย์นอกพินัยกรรมซึ่งตกได้แก่ทายาทโดยธรรมนั้น นักศึกษาต้องยกมาตราที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทายาทโดยธรรม การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม การเสียสิทธิในมรดกของทายาท เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ข้อสอบให้วินิจฉัย





กฎหมายอาญา 1

อาจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

นายกมลขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง บังเอิญมีสุนัขวิ่งตัดหน้ากระทันหัน นายกมลจึงหลบสุนัข รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง นายกมลได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกขาขวาแตกหักหมด หน่วยกู้ชีพพบเห็นเหตุการณ์จึงนำนายกมลส่งโรงพยาบาล นายแพทย์สุรเดชผู้ทำการรักษามีความเห็นว่าจะต้องตัดขาขวาของนายกมลทิ้งมิเช่นนั้นนายกมลจะไม่มีโอกาสรอดชีวิต นายแพทย์สุรเดชแจ้งเรื่องดังกล่าวให้นายกมลทราบ แต่นายกมลไม่ยินยอมเพราะไม่อยากเป็นคนพิการ ต่อมานายกมลเสียเลือดมากจนหมดสติไป นายแพทย์สุรเดชจึงตัดสินใจทำการผ่าตัดขาขวาของนายกมลออกไปเพื่อช่วยชีวิตของนายกมล นายแพทย์สุรเดชต้องรับผิดชอบอาญาในการตัดขาของนายกมลหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

มาตรา 67 ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น

- (1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ
 - (2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
- ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

วินิจฉัย

การกระทำด้วยความจำเป็นถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษตามกฎหมาย กล่าวคือ การกระทำนั้นยังคงเป็นความผิดอยู่เพียงแต่กฎหมายยกเว้นโทษให้ ซึ่งการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นนั้นผู้กระทำจะต้องรู้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดแต่จำต้องกระทำเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นได้ และได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุ หลักสำคัญประการหนึ่งในการอ้างการกระทำผิดด้วยความจำเป็นคือผู้นั้นจะต้องไม่เป็นผู้ก่อภยันนั้นขึ้นมาเสียเอง

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การกระทำของนายแพทย์สุรเดชที่ผ่าตัดขาขวาของนายกมลออกโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นแม้ว่าจะเป็นความผิดก็ตาม แต่เป็นการที่จำต้องกระทำเพื่อช่วยชีวิตนายกมลให้พ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง และการตัดขาขวาก็คือเพียงหนทางเดียวซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นได้ ทั้งนี้ อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากความประมาทของนายกมลเองไม่ใช่อำนาจการกระทำของนายแพทย์สุรเดช การผ่าตัดขาของนายกมลออกเพื่อรักษาชีวิตจึงเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุ ทำให้นายแพทย์สุรเดชไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 67

สรุป

ดังนั้น นายแพทย์สุรเดชไม่ต้องรับโทษในการตัดขาของนายกลมตามที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น

วิเคราะห์ข้อสอบ

การกระทำความผิดด้วยความจำเป็นกับความยินยอมให้กระทำนั้นมีความใกล้เคียงกับการกระทำที่ผู้เสียหายยินยอมให้กระทำ เช่น การกระทำของแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยา การผ่าตัด หรือการกระทำอื่นใดกับร่างกายคนไข้เพื่อการรักษาโรค ถ้าแพทย์กระทำด้วยความยินยอมของคนไข้อย่อมไม่มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ การกระทำของแพทย์ดังกล่าวเป็นเหตุยกเว้นความผิดเพราะเป็นความยินยอมที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ถ้าแพทย์จำต้องกระทำเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ เช่น แพทย์จำต้องทำการผ่าตัดคนไข้ที่สิ้นสติสลบไปโดยคนไข้ไม่ยินยอม เช่นนี้เป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา 67 (2) ซึ่งต้องประกอบด้วย 1) เป็นการป้องกันภัยอันตรายที่เกิดกับผู้อื่น 2) เป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง 3) เป็นการกระทำที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยวิธีการอื่นใด 4) ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นมิได้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตน และ 5) ได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุ ผู้กระทำจึงไม่ต้องรับโทษ กล่าวคือ การกระทำความผิดดังกล่าวแม้จะเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ อย่างไรก็ตามกรณีการกระทำความผิดเกิดขึ้นโดยผู้เสียหายยินยอมแต่ผู้กระทำไม่อาจอ้างความยินยอมของผู้เสียหายเพื่อเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้ เช่น ผู้เสียหายยินยอมให้ผู้กระทำยิงปืนใส่ตนเพราะเชื่อว่าตนอยู่ยงคงกระพัน ถ้าผู้กระทำยิงแล้วผู้เสียหายถึงแก่ความตายจะอ้างความยินยอมของผู้เสียหายเป็นเหตุยกเว้นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา 288 ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ เนื่องจากความยินยอมเช่นนี้หาใช่เหตุทำให้การกระทำที่เป็นความผิดกลายเป็นการกระทำที่ไม่เป็นความผิดไปได้ และเป็นความยินยอมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกด้วย

จากการตรวจสอบข้อสอบอัตนัยพบว่าคำถามข้อนี้นักศึกษาตอบผิดกันมาก เช่น นักศึกษาบางคนตอบว่า นายแพทย์สุรเดชมีหน้าที่ในการป้องกันผลไม่ให้นายกลมถึงแก่ความตายแล้วโดยอ้างหลักกฎหมายมาตรา 59 วรรคท้าย หากไม่กระทำการผ่าตัดขานายกลมแล้วจะเป็นการงดเว้นการที่จะต้องป้องกันผล บางคนตอบว่าการกระทำของนายแพทย์สุรเดชไม่ต้องรับผิดเพราะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68 ก็มีบางคนตอบว่า การกระทำของนายแพทย์สุรเดชต้องรับผิดเพราะได้กระทำไปโดยปราศจากความยินยอมจากนายกลม ตลอดจนไม่ได้รับความยินยอมจากญาติของนายกลมด้วย และบางคนก็ตอบว่า การกระทำของนายแพทย์สุรเดชไม่ต้องรับผิดเพราะได้กระทำตามจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ สาเหตุสำคัญที่ทำให้นักศึกษาตอบผิดในข้อนี้ คือ ความไม่เข้าใจเรื่องการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นกับความยินยอมให้กระทำ หากนักศึกษาไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่ยกหลักมาตรา 67 (2) มาตอบ และไม่สามารถเชื่อมโยงหลักกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อจะวินิจฉัยปัญหาได้ หรือวินิจฉัยแล้วก็ไม่ตรงประเด็น อีกทั้งยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สรุปคำตอบผิด เพราะเข้าใจโดยแท้ว่าการกระทำด้วยความจำเป็นนั้นเป็นเหตุยกเว้นความผิด ซึ่งที่ถูกต้องควรตอบว่าการกระทำความผิดเป็นเหตุยกเว้นโทษแต่ นักศึกษากลับตอบว่าเป็นเหตุยกเว้นความผิด

หวังว่าการวิเคราะห์ข้อสอบในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการจะศึกษาวิชากฎหมายไม่มากนักน้อย



กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นางสาวฟ้าถูกนายเดียวยทำร้ายร่างกายจึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ต.สันต์ เพื่อให้จับกุมตัวนายเดียวมาดำเนินคดี นางสาวฟ้าได้มอบเงินให้ ร.ต.ต. สันต์ 20,000 บาท และบอกให้ ร.ต.ต. สันต์ รับผิดชอบการจับกุมตัวนายเดียวยโดยเร็ว เพราะเกรงว่านายเดียวยจะย้อนกลับมาทำร้ายตนอีก ร.ต.ต. สันต์ เห็นว่านางสาวฟ้าให้เงินมาโดยมิได้ต้องการให้ตนกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดจึงรับเงินไว้ ดังนี้ นางสาวฟ้า และ ร.ต.ต. สันต์ ต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 144) บัญญัติว่า “ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน... เพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นางสาวฟ้าถูกนายเดียวยทำร้ายร่างกาย จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ต.สันต์ เพื่อให้จับกุมตัวนายเดียวมาดำเนินคดี โดยนางสาวฟ้าได้มอบเงินให้ ร.ต.ต.สันต์ 20,000 บาท ถือว่านางสาวฟ้าได้ให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานแล้ว แต่การให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานนั้น ก็เพื่อให้ ร.ต.ต. สันต์ รับผิดชอบการจับกุมนายเดียวยโดยเร็ว เพราะเกรงว่านายเดียวยจะย้อนกลับมาทำร้ายตนอีก จึงมิใช่เป็นการให้ทรัพย์สินเพื่อให้เจ้าพนักงานกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ แต่เป็นการให้กระทำการอันชอบด้วยหน้าที่ ดังนั้น การกระทำของนางสาวฟ้าจึงไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด นางสาวฟ้าไม่ต้องรับผิดทางอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 149) บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ”

สำหรับ ร.ต.ต. สันต์ นั้น การที่ ร.ต.ต.สันต์ รับเงินที่นางสาวฟ้าให้ก็ถือว่า ร.ต.ต.สันต์ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานรับทรัพย์สินสำหรับตนเองแล้ว ซึ่งเป็นการรับไว้โดยมิชอบ เพราะไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบแบบแผนที่จะรับ แม้จะรับไว้เพื่อรับผิดชอบการจับกุมตัวนายเดียวมาดำเนินคดี ถือเป็นการกระทำในตำแหน่งโดยชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม ก็ถือว่ามีความผิดแล้ว เพราะความผิดฐานนี้เพียง

เจ้าพนักงานรับทรัพย์ไว้โดยมิชอบเพื่อกระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ก็ถือว่ามีความผิดแล้ว ดังนั้น ร.ต.ต.สันต์ จึงมีความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบนตามกฎหมายดังกล่าว มาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานกับความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน เพราะความผิดทั้งสองนี้มักจะเกิดคู่กันเสมอ กล่าวคือ เมื่อมีผู้ให้สินบน ก็จะมีผู้รับสินบน ซึ่งทั้งผู้ให้และผู้รับก็จะมี ความผิด แต่กฎหมายกำหนดองค์ประกอบของการที่จะต้องรับผิดไว้แตกต่างกัน ในความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานนั้น ผู้ให้สินบนจะมีความผิดก็ต่อเมื่อ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้เจ้าพนักงานกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำความผิดด้วยหน้าที่เท่านั้น ดังนั้น ถ้าบุคคลใดให้สินบนแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้เจ้าพนักงานกระทำการอันชอบด้วยหน้าที่ก็จะเป็นการไม่มีความผิด แต่กรณีเจ้าพนักงานรับสินบนนั้น กฎหมายกำหนดว่าเจ้าพนักงานที่เรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็มีความผิดทั้งสิ้น

นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตอบมา มักจะตอบว่านางสาวฟ้าผิดให้สินบน ส่วน ร.ต.ต.สันต์ ผิดรับสินบน ทั้งนี้เพราะนักศึกษานี้่านกฎหมายไม่ละเอียดพอ ซึ่งถ้านักศึกษานี้่านละเอียดแล้ว ก็จะเห็นข้อแตกต่างของความผิดทั้งสองมาตรานี้และไม่ตอบผิด

ในการสอบครั้งต่อไปขอให้ให้นักศึกษานี้่านกฎหมายให้ละเอียดรอบคอบ พยายามจำตัวบทกฎหมายให้ได้มาก ๆ ก็จะไม่พลาดในการสอบแน่นอนค่ะ



กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน

คำถาม

แดงตกลงด้วยวาจาขายบ้านพร้อมที่ดินให้ดำในราคา 1 ล้านบาท โดยดำผู้ซื้อเป็นฝ่ายรับภาระค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และต้องชำระราคาทั้งหมดภายในสิ้นปี ปรากฏว่าจนถึงสิ้นปี ดำชำระราคาไปเพียง 1 แสนบาทนั้น เนื่องจากหมุนเงินไม่ทันดำจึงขอเงิน 1 แสนบาท คืน โดยอ้างว่าสัญญาซื้อขายด้วยวาจาตกเป็นโมฆะ เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า แแดงจะมีข้อต่อสู้อย่างไรหรือไม่

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง บัญญัติว่า “สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค้ำประกันในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ หรือได้วางประจำไว้หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่”

ตามปัญหา แแดงตกลงด้วยวาจาขายบ้านพร้อมที่ดินให้ดำในราคา 1 ล้านบาท โดยดำผู้ซื้อเป็นฝ่ายรับภาระค่าธรรมเนียมการซื้อขาย การกำหนดให้ผู้ซื้อเป็นฝ่ายรับภาระค่าธรรมเนียม แสดงว่าคู่กรณีประสงค์จะไปทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 805/2539) จึงเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อดำชำระราคาไปเป็นจำนวน 1 แสนบาทแล้ว เห็นได้ว่าได้มีการชำระหนี้บางส่วน จึงฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสองดังกล่าว การตกลงซื้อขายที่ดินระหว่างแดงกับดำเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย มิใช่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่อย่างใด แม้จะตกลงด้วยวาจา แต่ได้มีการชำระหนี้บางส่วนแล้วก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้ หากตกเป็นโมฆะแต่ประการใด

ฉะนั้น แแดงจึงมีข้อต่อสู้ว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่ตกเป็นโมฆะ

วิเคราะห์

ในข้อนี้เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย โดยหากพิจารณาว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย และมีการชำระราคาถือได้ว่าการชำระหนี้บางส่วน จึงสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ มิใช่กรณีการเป็นโมฆะตามสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ประการใด

แต่ก็ยังมึ้นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่วินิจฉัยว่าสัญญาระหว่างแดงกับดำเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เมื่อตกลงซื้อขายกันด้วยวาจาถือว่าไม่ทำตามแบบตามมาตรา 456 วรรคหนึ่ง มีผลทำให้สัญญาเป็นโมฆะ ทั้งนี้ นักศึกษาก็ได้ยกหลักกฎหมายตามมาตรา 456 วรรคหนึ่ง มาด้วย ทำให้พลาดการได้คะแนนในข้อนี้ไป

อย่างไรก็ตาม ยังมีนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งที่วินิจฉัยถูกต้องว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย แต่กลับพลาดที่ไปวินิจฉัยว่าการตกลงซื้อขายด้วยวาจา ทำให้ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามมาตรา 456 วรรคสอง เนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด โดยไม่วินิจฉัยว่าการชำระราคาไปดังกล่าวนั้น เป็นการชำระหนี้บางส่วนที่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เช่นกัน กรณีนี้จึงทำให้นักศึกษาที่วินิจฉัยดังกล่าวได้คะแนนไม่เต็ม

คำถาม

เนื่องจากนายรัชชาซึ่งเป็นลูกชายของนางกิ่งแก้วกำลังจะกลับจากต่างประเทศ นางกิ่งแก้วจึงตกลงว่าจ้างนายรัชชาซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาต่อเติมบ้านโดยให้สร้างห้องเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ห้อง ในราคา 500,000 บาท เพื่อให้ให้นายรัชชาได้อยู่อย่างเป็นส่วนตัว นางกิ่งแก้วตกลงกับนายรัชชาว่า นางกิ่งแก้วจะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างเอง และจะส่งมอบงานกันภายใน 2 เดือน แต่เมื่อนายรัชชาได้ทำการต่อเติมห้องไปได้ประมาณ 1 เดือน นางกิ่งแก้วได้ล้มเปิดเตาแก๊สในบ้านทิ้งไว้ จึงทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านทั้งหมด รวมทั้งส่วนห้องที่นางกิ่งแก้วจ้างนายรัชชาให้ต่อเติมด้วย ให้ท่านวินิจฉัยว่า นายรัชชาต้องซ่อมแซมส่วนห้องต่อเติมที่ได้รับ ความเสียหายให้อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ และนางกิ่งแก้วต้องจ่ายค่าจ้างให้นายรัชชาหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ปพพ. มาตรา 587 บัญญัติว่า “อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น”

ปพพ. มาตรา 604 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างทำนั้นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซ้ ท่านว่าความวินาศนั้นตกเป็นพับแก่ผู้ว่าจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้เป็นเพราะการกระทำของผู้รับจ้าง

ในกรณีเช่นว่านี้ สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้ เว้นแต่ความวินาศนั้นเป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้าง”

วินิจฉัย

กรณีตามโจทย์ การที่นางกิ่งแก้วตกลงว่าจ้างนายธัชซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาต่อเติมบ้านโดยให้สร้างห้องเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ห้อง ในราคา 500,000 บาท ถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของตาม ปพพ. มาตรา 587 เนื่องจากนายธัชซึ่งเป็นผู้รับจ้างตกลงรับจะทำงาน คือต่อเติมบ้านจนสำเร็จให้แก่นางกิ่งแก้วซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง และนางกิ่งแก้วซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างก็ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงาน คือได้ห้องใหม่ที่ต่อเติมอีก 1 ห้อง

จากข้อเท็จจริง การที่นางกิ่งแก้วเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างจัดหาสัมภาระเอง ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าก่อนที่จะได้มีการส่งมอบห้องที่ต่อเติมใหม่นั้นได้เกิดเพลิงไหม้จนทำให้ห้องใหม่ที่กำลังก่อสร้างได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่ถือได้ว่าการที่จ้างทำนั้นพังทลายหรือบอบสลายลงก่อนได้รับมอบกัน ดังนั้น ตาม ปพพ. มาตรา 604 วรรคแรก เมื่อความวินาศที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดเพราะการกระทำของผู้รับจ้าง เพราะการที่เกิดไฟไหม้นั้นเกิดจากการกระทำของนางกิ่งแก้วผู้ว่าจ้าง ดังนั้น ความวินาศจึงตกเป็นพับแก่ผู้ว่าจ้าง กล่าวคือ นายธัชซึ่งเป็นผู้รับจ้างไม่ต้องซ่อมแซมส่วนห้องต่อเติมที่ได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าจ้างนั้น เมื่อความวินาศเกิดเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้าง กล่าวคือนางกิ่งแก้วเป็นผู้ที่ทำให้ไฟไหม้ห้องที่ต่อเติม ดังนั้น ตาม ปพพ. มาตรา 604 วรรคสอง นางกิ่งแก้วยังต้องใช้ค่าสินจ้างอยู่ คือ นางกิ่งแก้วยังต้องจ่ายค่าจ้างให้นายธัชอยู่

ดังนั้น นายธัชไม่ต้องซ่อมแซมส่วนห้องต่อเติมที่ได้รับความเสียหาย แต่นางกิ่งแก้วยังต้องจ่ายค่าจ้างในการต่อเติมห้องให้นายธัชอยู่

วิเคราะห์

คะแนนหลักกฎหมายในข้อนี้จะเน้นหนักไปที่มาตรา 604 เป็นสำคัญ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ทำข้อสอบข้อนี้ได้ และจำนวนไม่น้อยที่ได้คะแนนดี ทั้งการวางหลักกฎหมายและวินิจฉัย

แต่ก็ยังมึ้นนักศึกษาที่วินิจฉัยว่าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ ทำให้การพิจารณาผิดพลาดไปหรือมีนักศึกษาที่ไม่ยกหลักกฎหมายแต่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัววินิจฉัยว่าผู้รับจ้างไม่ต้องซ่อมแซม และผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องใช้สินจ้าง ทำให้ได้คะแนนไม่มาก ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งไปวินิจฉัยว่าสัญญานี้เป็นสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาด



กฎหมายพาณิชย์ 2

อาจารย์จาตุรนต์ บุญยธนะ

คำถาม

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ดาราขายรถยนต์คันหนึ่งให้ดาวเรือง โดยแจ้งว่ารถยนต์คันดังกล่าวสภาพดีไม่เคยประสบอุบัติเหตุรถชนมาก่อน และในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ดาวเรืองทำสัญญาประกันวินาศภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัย โดยในขณะทำสัญญาประกันวินาศภัยดาวเรืองและดาราแจ้งกับบริษัทผู้รับประกันภัยว่ารถยนต์ดังกล่าวสภาพดีไม่เคยประสบอุบัติเหตุรถชนมาก่อน ทั้งที่ดาราทราบดีว่าก่อนหน้านี้รถยนต์ดังกล่าวเคยประสบอุบัติเหตุรถชนเสียหายอย่างหนัก ต่อมาในวันที่ 20 กันยายน 2556 บริษัทผู้รับประกันภัยสืบทราบถึงเหตุดังกล่าวและต้องการจะบอกเลิกสัญญาประกันภัย

ดังนี้ บริษัทผู้รับประกันภัยสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

หลักกฎหมาย

ปพพ. มาตรา 865 ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือ ให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็น ความเท็จไซ้ร่ทำนว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ

ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกกล่าวภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกกล่าวได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายใน กำหนดห้าปีนับแต่วันทำสัญญาก็ดี ทำนว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป

ปพพ. มาตรา 865 ดังกล่าวกำหนดหน้าที่สำคัญของผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผยข้อความจริงตาม “หลักสุจริตอย่างยิ่ง” (Principle of Utmost Good Faith) ของสัญญาประกันภัย โดยข้อความจริงนั้นต้องเป็นข้อสาระสำคัญที่ถึงขั้นจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา จึงจะทำให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ และหากผู้รับประกันภัยไม่บอกกล่าวสัญญาภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกกล่าว หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันทำสัญญา ถือว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป

วินิจฉัย

ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักสุจริตอย่างยิ่งคือผู้เอาประกันภัย เมื่อดาวเรืองทำสัญญาประกันวินาศภัยภายหลังจากได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จากดาราโดยการซื้อขาย เฉพาะดาวเรืองผู้เอาประกันภัยเท่านั้นที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักสุจริตอย่างยิ่ง และเมื่อดาวเรืองปฏิบัติตามหลักดังกล่าวแล้ว สัญญาประกันวินาศภัยจึงไม่ตกเป็นโมฆียะ ตาม ปพพ. มาตรา 865

อนึ่งดารามีใช้ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวที่จะต้องปฏิบัติตามหลักสุจริตอย่างยิ่งตาม ปพพ. มาตรา 865 แม้ดาราจะปกปิดไม่เปิดเผยข้อความจริงก็ตาม อีกทั้งข้อความจริงที่ว่า “รถยนต์เคยประสบอุบัติเหตุรถชนเสียหายอย่างหนัก” ข้อความจริงดังกล่าวมิใช่ข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญอันจะมีผลเป็นการจูงใจบริษัทผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นกว่าที่เรียกไว้หรือเป็นเหตุบอกปิดไม่ยอมทำสัญญาด้วย เพียงแต่มีผลให้บริษัทผู้รับประกันภัยไม่ยอมรับประกันภัยในจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้เท่านั้น กรณีจึงไม่ต้องด้วย ปพพ. มาตรา 865 (เทียบเคียงฎีกาที่ 918/2519) ดังนี้แม้ในวันที่ 20 กันยายน 2556 บริษัทผู้รับประกันภัยจะสืบทราบถึงการปกปิดข้อความจริงดังกล่าวก็มีอาจบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ ตาม ปพพ. มาตรา 865

สรุป

บริษัทผู้รับประกันภัยมีอาจดำเนินการบอกเลิกสัญญาประกันวินาศภัยดังกล่าวได้ ตาม ปพพ. มาตรา 865

วิเคราะห์

ก่อนทำการวินิจฉัยนักศึกษาต้องยก ปพพ. มาตรา 865 เรื่องหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย และที่สำคัญนักศึกษาต้องอธิบายถึงหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย นักศึกษาจำนวนมากจะยกมาตรา 865 แต่ไม่อธิบายความหมายของหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย และนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งยกมาตรา 865 แต่ไม่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระของบทบัญญัติดังกล่าว เช่น อ้างถึงผลของสัญญาประกันภัยว่าตกเป็น “โมฆะ” เป็นต้น ทำให้เสียคะแนน

การวินิจฉัยนั้นนักศึกษาต้องแยกประเด็นเป็น 2 ประเด็นให้ชัดเจน คือ ประเด็นที่หนึ่ง บุคคลผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าในกรณีสัญญาประกันวินาศภัยนั้น เฉพาะดาวเรืองผู้เอาประกันภัยซึ่งมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยเท่านั้นที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักสุจริตอย่างยิ่ง โดยนักศึกษาจำนวนมากไม่ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้จึงวินิจฉัยผิดพลาดว่าทั้งผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามหลักสุจริตอย่างยิ่ง ทำให้เสียคะแนน

และประเด็นที่สอง ข้อความจริงที่ต้องเปิดเผยตามหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัย นักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าข้อความจริงที่ต้องเปิดเผยนั้น คือ ข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญอันจะมีผลเป็นการจูงใจบริษัทผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นกว่าที่เรียกไว้หรือเป็นเหตุบอกปิดไม่ยอมทำสัญญาด้วย แต่ข้อความจริงตามโจทย์นั้นไม่อาจถือเป็นข้อความจริงลักษณะดังกล่าว โดยนักศึกษาจำนวนมากเข้าใจไม่ถูกต้องวินิจฉัยว่าการไม่เปิดเผยข้อความจริงดังกล่าวเป็นผลให้สัญญาประกันวินาศภัยดังกล่าวตกเป็นโมฆียะ อีกทั้งนักศึกษาจำนวนหนึ่งเข้าใจผิดว่าผลดังกล่าวทำให้สัญญาประกันวินาศภัยตกเป็นโมฆะซึ่งไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ศึกษาอีกจำนวนหนึ่งยังวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นทำให้เสียคะแนน





กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

อาจารย์ธวัช เนติโพธิ์

ในการสอบอรรถนัยของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 นั้น นักศึกษาจะสังเกตว่ามีข้อสอบอรรถนัย 3 ข้อเสมอ โดยมีเนื้อหาสาระแต่ละข้อดังนี้

ข้อ 1. จะเป็นคำถามในเรื่องวิธีพิจารณาสำนวนในศาลชั้นต้น (หน่วยที่ 1-2) ได้แก่เรื่อง ฟ้องและฟ้องซ้อน ทั้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง และในเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด (หน่วยที่ 4) เป็นหลัก

ข้อ 2. จะเป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา (หน่วยที่ 5) และเรื่องการบังคับคดีที่มีผลกระทบบุคคลภายนอก (หน่วยที่ 8) ได้แก่เรื่องร้องขอชดเชยทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเปลี่ยนทรัพย์ ร้องขอถอนส่วน เป็นต้น เป็นหลัก

ข้อ 3. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ซึ่งข้อนี้จะมีเนื้อหากว้างมากหน่อย (ตั้งแต่หน่วยที่ 10-12) แต่ไม่เคยออกสอบอรรถนัยเรื่องฟื้นฟูกิจการ

ทุกส่วนที่กล่าวแล้วนี้นอกจากจะออกเป็นข้อสอบอรรถนัยแล้วยังนำไปออกสอบเป็นข้อสอบปรนัยอีกด้วย และเนื้อหาสาระอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึงไว้ก็จะออกเป็นข้อสอบปรนัยทั้งสิ้น ฉะนั้น นักศึกษาจึงต้องอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาทั้งหมดจะทั้งหน่วยใดหน่วยหนึ่งไปไม่ได้เลย

ในการสอบไล่ภาค 1/2556 นี้แนวข้อสอบอรรถนัยก็ยังคงเป็นไปในกลุ่มเนื้อหาสาระที่กล่าวแล้วข้างต้น แต่จะนำเฉพาะข้อสอบข้อ 2 มาวิเคราะห์วิจารณ์ให้นักศึกษาทราบดังนี้

ข้อ 2. ก. จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอชดเชยทรัพย์ และตอบคำถามต่อไปนี้

- ก) ผู้ที่สามารถยื่นคำร้องขอชดเชยทรัพย์เป็นใครบ้าง
- ข) เหตุผลที่ต้องอ้างในการร้องขอชดเชยทรัพย์มีอะไรบ้าง
- ค) กำหนดเวลาในการยื่นคำร้องขอชดเชยทรัพย์เป็นอย่างไร

(10 คะแนน)

ข. นายมะพร้าวกับนางสาวสมเป็นสองคนพี่น้องเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินว่างเปล่าแปลงหนึ่ง ซึ่งได้รับมรดกจากมารดา โดยมีส่วนเป็นเจ้าของเท่า ๆ กัน แต่ยังมีได้ตกลงกันชัดเจนว่าส่วนใดเป็นของใคร และยังมีได้แบ่งแยกกัน ต่อมานายมังกร เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของนายมะพร้าวได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดเอาที่ดินแปลงนี้ออกขายทอดตลาด นางสาวสมเห็นเห็นว่าตนมิได้เป็นลูกหนี้ของนายมังกร จึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการสั่งให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดตามมาตรา 288 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่นนี้ นางสาวสมเป็นจะทำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (10 คะแนน)

ข้อวิจารณ์

ข้อสอบข้อนี้มีแนวคำถามคล้ายกับที่เคยออกสอบไปแล้วในหลายภาคที่ผ่านมา คือมีคำถามย่อย 2 ข้อ ซึ่งนักศึกษาอาจคิดว่ายากแต่ความจริงแล้วจะช่วยให้นักศึกษาได้คะแนนง่ายขึ้นเพราะในคำถามข้อแรกนั้นเป็นการบังคับให้นักศึกษาต้องวางหลักกฎหมายในเรื่องที่ถามเสียก่อน และยังมีคำถามย่อยเพื่อให้นักศึกษาต้องตอบหลักกฎหมายให้ครอบคลุมทุกประเด็น ฉะนั้น นักศึกษาที่เตรียมตัวมาดีก็จะได้คะแนนในส่วนนี้ไปถึงระหว่าง 8-10 คะแนน แม้ตอบคำถามในข้อย่อย ข. (ซึ่งก็เป็นเรื่องเดียว-หลักกฎหมายเดียวกับข้อย่อย ก.) ผิดก็ยังได้คะแนนในส่วนแรกนี้อยู่ ดังจะเห็นได้จากธงคำตอบดังต่อไปนี้

ธงคำตอบ

ก. จากมาตรา 288 ที่บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๕๕ ถ้าบุคคลใดกล่าวอ้างว่า จำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ ก่อนที่ได้เอาทรัพย์สิน เช่นว่านี้ออกขายทอดตลาด หรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น บุคคลนั้นอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้ปล่อยทรัพย์สินเช่นว่านั้น ฉะนั้น จึงตอบคำถามได้ดังนี้

ก) ผู้ที่สามารถยื่นคำร้องขจัดทรัพย์สินเป็นไครบ้าง **ตอบ** คือผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิของตนตามมาตรา 55 ฉะนั้น ผู้ร้องขจัดทรัพย์สินอาจเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้อื่นที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง เช่นเป็นผู้เช่าซื้อ หรือเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นก็ไ้

ข) เหตุผลที่ต้องอ้างในการร้องขจัดทรัพย์สินมีอย่างไรบ้าง **ตอบ** ต้องอ้างว่าจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้

ค) กำหนดเวลาในการยื่นคำร้องขจัดทรัพย์สินเป็นอย่างไร **ตอบ** ก่อนที่ได้เอาทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาด หรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น

สำหรับในข้อย่อย ข. ซึ่งเป็นคำถามที่มีข้อเท็จจริงประกอบที่เรามักเรียกกันทั่วไปว่าคำถามตุ๊กตานั้น นักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีข้อความที่เป็นสาระสำคัญอยู่คือ “นายมะพร้าวกับนางสาวสมแป้นสองคนพี่น้องเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินว่างเปล่าแปลงหนึ่ง....” เพราะการร้องขจัดทรัพย์สินนั้น ผู้ร้องจะต้องกล่าวอ้างว่าจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่ยึดไว้เป็นสำคัญ หากทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดมานั้นเป็นของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วก็จะร้องขจัดทรัพย์สินไม่ได้ เพราะทรัพย์สินนั้นเป็นของจำเลย แม้จำเลยจะมีได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยลำพัง แต่เป็นเจ้าของรวมกับบุคคลอื่นก็ตาม เจ้าของรวมคนอื่นจะมาร้องขจัดทรัพย์สินไม่ได้ (จากเอกสารการสอน หน้า 8-14 และกิจกรรมท้ายเรื่อง 8.1.2) ได้แต่จะร้องขอในส่วนของตนตามมาตรา 287 เท่านั้น (ถ้านักศึกษาไม่ตอบข้อความนี้มาก็ไม่ตัดคะแนนใด ๆ)

ฉะนั้น ตามอุทธรณ์ เมื่อนายมะพร้าวกับนางสาวสมแป้นเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินที่ถูกยึดทรัพย์สินไว้ นางสาวสมแป้นซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อีกคนหนึ่งจะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดตามมาตรา

288 หรือที่เรียกกันว่าร้องชดทรัพย์ไม่ได้ ตอบเพียงเท่านี้ก็จะได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็มแล้ว

อนึ่ง ข้อเท็จจริงที่ระบุไว้ในข้อสอบว่า**แต่ยังมีได้ตกลงกันชัดเจนว่าส่วนใดเป็นของใคร และยังมีได้แบ่งแยกกัน** ก็ให้ไว้เพื่อป้องกันมิให้นักศึกษาสับสนเท่านั้น เพราะเหตุว่าแม้โดยทั่วไปหากเป็นกรรมสิทธิ์รวมแล้วเจ้าของร่วมอีกคนหนึ่งจะร้องชดทรัพย์ไม่ได้ก็ดี แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าทรัพย์นั้นได้มีการแบ่งแยกกันเป็นสัดส่วนแล้ว การบังคับคดีจะต้องกระทำเฉพาะส่วนของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น ถ้าไปยึดมาทั้งหมดเจ้าของรวมคนอื่นก็อาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดได้ (จากเอกสารการสอน หน้า 8-14 อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 263/2520 , 3139/2537 , 2451/2548) ฉะนั้นเมื่อข้อเท็จจริงระบุไว้ชัดเจนว่าที่ดินพิพาทนี้นายมะพร้าวและนางสาวส้มแป้นยังมีได้ตกลงกันว่าส่วนใดเป็นของใคร และยังมีได้แบ่งแยกกันเป็นสัดส่วน นางสาวส้มแป้นจึงร้องชดทรัพย์ไม่ได้

มีนักศึกษาท่านหนึ่งตอบถูกหมดทั้งข้อ ก.และข้อ ข. และยังตอบเพิ่มมาด้วยว่า หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนเป็นว่านายมะพร้าวกับนางสาวส้มแป้นได้มีการแบ่งแยกการถือครองที่ดินพิพาทกันเป็นสัดส่วนแล้ว ในกรณีนี้ นางสาวส้มแป้นจึงอาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึดได้ ดังนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากและได้คะแนนเต็ม 20 คะแนนไป อย่างไรก็ดี ในการตรวจข้อสอบครั้งนี้ขอเพียงนักศึกษาตอบถูกหมดทั้งข้อ ก.และข้อ ข. ดังกล่าวแล้วแม้จะไม่ข้อความข้างต้นนี้มาด้วยก็มีโอกาสได้คะแนนเต็มเช่นกัน

ตอบข้อสอบอัตนัยไม่ว่าวิชาใด และไม่ว่าข้อสอบจะแยกถามเป็นข้อย่อยดังที่ยกมาวิจารณ์ไว้นี้หรือไม่ก็ตาม นักศึกษาต้องอธิบายข้อกฎหมายไว้ก่อนเสมอ ยิ่งวางหลักกฎหมายไว้แล้วอธิบายประกอบด้วยยิ่งดี เพราะแม้จะตอบผิดตรง ก็ยังพอจะได้คะแนนในส่วน of ข้อกฎหมายบ้าง แต่ข้อกฎหมายที่ตอบต้องเป็นข้อที่ถามด้วย เช่น ถามเรื่องร้องชดทรัพย์ก็ต้องตอบในเรื่องร้องชดทรัพย์ ถ้าไปตอบเรื่องขอเฉลี่ยทรัพย์ แบบนี้จะไม่ได้คะแนนเลย





กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

อาจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

นายจอนเป็นโจทก์ฟ้องนายจิตและนายใจ เป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้นในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วสั่งประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาและศาลนัดสืบพยานโจทก์ ในวันนัดสืบพยานโจทก์ปรากฏว่า นายจอนและทนายความของนายจอนไม่มาศาลตามกำหนดนัดโดยไม่ทราบสาเหตุ ส่วนนายจิตมาศาลแต่ทนายใจไม่มาศาลเนื่องจากเจ้าพนักงานศาลยังส่งหมายเรียกให้ไม่ได้ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลย

ดังนี้ นายจอนจะร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
มาตรา 166 บัญญัติว่า “ถ้าโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด ให้ศาลยกฟ้องเสีย แต่ถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ จะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้

คดีที่ศาลได้ยกฟ้องดังกล่าวแล้ว ถ้าโจทก์มาร้องภายในสิบห้าวัน นับแต่วันศาลยกฟ้องนั้น โดยแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ ก็ให้ศาลยกคดีนั้นขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่

ในคดีที่ศาลยกฟ้องดังกล่าวแล้ว จะฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกไม่ได้ แต่ถ้าศาลยกฟ้องเช่นนั้น ในคดีซึ่งราษฎรเท่านั้นเป็นโจทก์ ไม่ตัดอำนาจพนักงานอัยการฟ้องคดีนั้นอีกเว้นแต่จะเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว”

มาตรา 181 บัญญัติว่า “ให้นำบทบัญญัติในมาตรา 139 และ 166 มาบังคับแก่การพิจารณาโดยอนุโลม”

จากบทกฎหมายดังกล่าว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ส่วนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 181 ให้นำหลักเกณฑ์เรื่องโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ตาม มาตรา 166 มาใช้บังคับกรณีโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดในชั้นพิจารณาด้วยโดยอนุโลม

กำหนดนัดในชั้นพิจารณา หมายถึง วันที่ศาลนัดให้โจทก์นำพยานของฝ่ายโจทก์มาสืบทุกนัดในชั้นพิจารณาคดี ไม่ว่าโจทก์จะได้สืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว หรือจำเลยจะไม่ได้มาศาลในวันนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์

ก็ตาม และเมื่อโจทก์ทราบนัดโดยชอบแล้ว โจทก์ต้องมาศาลตามนัด ถ้าโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดพิจารณา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 181 บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดหรือจะสั่งให้เลื่อนคดีก็ได้

ตามคำถาม ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องคดีที่นายจอนเป็นโจทก์ฟ้องนายจิตและนายใจเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และมีคำสั่งประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาแล้วนัดสืบพยานโจทก์ ต่อมาในวันสืบพยานโจทก์ปรากฏว่านายจอนโจทก์และทนายความของนายจอนไม่มาศาลโดยไม่ทราบเหตุขัดข้อง กรณีนี้ถือได้ว่าโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 181 ศาลมีอำนาจสั่งยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดหรือจะสั่งให้เลื่อนคดีก็ได้ แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่านายจิตจำเลยมาศาล แต่นายใจจำเลยอีกคนไม่มาศาล ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ ซึ่งการที่ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มีพยานมาสืบนั้นไม่ถูกต้อง เพราะถึงแม้ว่าโจทก์จะไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ก็ตาม แต่นายใจจำเลยอีกคนหนึ่งก็ไม่มาศาลด้วยเพราะยังส่งหมายเรียกให้ไม่ได้ ซึ่งการพิจารณาคดีกฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย จะกระทำลับหลังจำเลยไม่ได้ ดังนั้น เมื่อจำเลยบางคนไม่ได้มาศาล แม้โจทก์และพยานโจทก์จะมาศาลก็ไม่อาจสืบพยานโจทก์ได้ ศาลควรสั่งให้เลื่อนคดีไปก่อน ไม่ใช่สั่งยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ และเมื่อเป็นกรณีที่โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 181 ถึงแม้ว่าศาลได้พิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มีพยานมาสืบก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิของโจทก์ที่จะร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ศาลยกฟ้องโจทก์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคสอง

ดังนั้น นายจอนโจทก์จึงร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ เพราะเป็นกรณีที่โจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ นายจอนจะร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นคำถามเรื่อง นายจอนจะร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ นักศึกษาควรยกหลักกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถาม กล่าวคือ ถ้าโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดในชั้นพิจารณา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 181 ให้นำหลักเกณฑ์เรื่องโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ตาม มาตรา 166 มาใช้บังคับกรณีโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดในชั้นพิจารณาด้วยโดยอนุโลม และกรณีที่โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดพิจารณา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรค

หนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 181 บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดหรือจะสั่งให้เลื่อนคดีก็ได้

ประการที่สอง ประเด็นคำถามในเรื่องนี้มีประเด็นย่อยที่ต้องอธิบายและวินิจฉัยเป็นลำดับ คือ กรณีที่โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นจะต้องมีคำสั่งอย่างไรบ้าง ประการต่อมา ถ้าศาลสั่งยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด โจทก์มีสิทธิดำเนินการอย่างไรบ้าง ประการสุดท้าย ในวันสืบพยานโจทก์แม้โจทก์จะไม่ได้มาศาล แต่จำเลยก็ไม่ได้มาศาลด้วยเพราะยังส่งหมายเรียกให้ไม่ได้ ศาลควรจะสั่งอย่างไร

ประการที่สาม นักศึกษาหลายคนไม่สามารถตอบคำถามได้ เนื่องจากจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งมีนักศึกษาหลายคนหลงประเด็นไปตอบเรื่อง นายจอนโจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งได้หรือไม่

ประการที่สี่ มีนักศึกษาบางส่วนจับประเด็นปัญหาได้ แต่ไม่สามารถตอบคำถามได้ เพราะไม่ทราบว่า จะนำบทบัญญัติมาตราใดมาตอบ จึงตอบว่าให้นำหลักเรื่องทั้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ

ประการที่ห้า หลายคนวินิจฉัยผิด โดยวินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ ไม่ใช่กรณีที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องโดยอาศัยเหตุที่โจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 181 นายจอนจึงร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่หาได้ไม่

มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากตอบคำถามไม่ได้เลย เพราะไม่ทราบหลักกฎหมายและจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 และมาตรา 181 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง โจทก์ขาดนัดในชั้นใด ส่วนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติหลักการไว้ค่อนข้างกว้าง จึงจำเป็นต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลารว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริมเพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล

ข้อ 1. นักศึกษาจงอธิบายว่าประเทศไทยสมควรที่จะเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) หรือไม่อย่างไร และ การเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทย และหากประเทศไทยไม่เข้าเป็นสมาชิก จะมีผลอย่างไรต่อประเทศไทย

คำตอบ

ประเด็นปัญหา

1. อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) มีสถานะทางกฎหมายอย่างไร
2. สถานะของ อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) มีผลต่อประเทศไทยอย่างไร
3. สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) มีอย่างไรบ้าง ซึ่งหากประเทศไทยเป็นสมาชิกจะต้องดำเนินการอย่างไร และจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร
4. หากประเทศไทยไม่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) จะมีผลอย่างไร

หลักกฎหมาย

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสนธิสัญญา

1. หลักสัญญาย่อมผูกพัน pacta sunt servanda หรือสนธิสัญญาย่อมได้รับการเคารพ และปฏิบัติตามนอกจากหลักการปฏิบัติโดยสุจริต หลักการแสดงความเจตนาโดยสมัครใจ แล้วหลักสัญญาย่อมผูกพันได้รับการรับรองในอนุสัญญากรุงเวียนนาในบทนำ วรรค 3 และยังปรากฏในมาตรา 26 และมาตรา 27 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่า รัฐไม่อาจจะกล่าวอ้างบทบัญญัติของกฎหมายภายในเพื่อเป็นข้ออ้าง หรือเหตุผลในการที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตามสนธิสัญญา ย่อมแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าโดยหลักการแล้วหากรัฐเข้า

ผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามสนธิสัญญา ผลของสนธิสัญญานั้นย่อมผูกพันรัฐนั้น จะกล่าวอ้างเหตุอื่นใดเพื่อที่จะไม่ปฏิบัติตามผลของสนธิสัญญา ย่อมไม่ได้ pacta sunt servanda เป็นหลักการที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนับว่าสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลัก pacta sunt servanda นี้จะถูกจำกัดเฉพาะในกรณีที่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป ที่สำคัญยิ่งเกิดขึ้นใหม่ลบล้างหลักกฎหมายเดิม ความผูกพันตามสนธิสัญญา (ที่จะต้องเคารพตามหลัก pacta sunt servanda นี้) ซึ่งไปขัดกับหลักกฎหมายทั่วไปที่เกิดขึ้นใหม่ สนธิสัญญานี้ย่อมสิ้นผล ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 64

2. การประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศขึ้นมาเป็นสนธิสัญญา ย่อมแสดงว่ามหาชนระหว่างประเทศเห็นว่าหลักกฎหมายทั้งหลายที่ประมวลขึ้นมานั้น เป็นสิ่งอันพึงปรารถนาของสังคมระหว่างประเทศ ดังนั้นรัฐใดถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายนั้นย่อมเป็นฝ่ายที่มีความชอบธรรมในสายตาของมหาชนระหว่างประเทศ และรัฐที่ละเมิดกฎหมายเหล่านั้นจะเป็นฝ่ายที่ขาดความชอบธรรมและเป็นที่รังเกียจของสังคมระหว่างประเทศ ยิ่งกว่านั้นการที่ในยุคปัจจุบัน ประเทศมหาอำนาจและองค์กรระหว่างประเทศมีส่วนที่เข้ามาคอยจับตาดูและผลักดันให้รัฐปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งที่อยู่ในรูปของสนธิสัญญา และ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

3. อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) มีสถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ที่รัฐทั้งหลายต้องปฏิบัติตามทั้งในฐานะที่เป็นรัฐภาคี และในฐานะที่เป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ซึ่งมีสาระที่สำคัญเกี่ยวกับทะเลอาณาเขตและเขตทางทะเล ดังต่อไปนี้

ทะเลอาณาเขต (The Territorial Sea)

เขตต่อเนื่อง (The Contiguous Zone)

ช่องแคบ (The Strait)

รัฐหมู่เกาะ (Archipelagos)

เขตประมง (The Fishing Zone)

เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (The Economic Exclusive Zone)

นอกจากนี้ยังมีสาระอื่นๆ ได้แก่ เรื่องสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรบนผิวดิน ใต้ผิวดิน และการแสวงหาประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม การทราบเขตทางทะเลจะทำให้ปัญหาเหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่าอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐ หรือ ภายใต้เขตอำนาจรัฐ อย่างไร หรือ เป็นเขตที่เป็นทะเลหลวง รวมทั้งเรื่องมรดกของมวลมนุษยชาติ ดังนั้นเบื้องต้นจึงจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับเขตทางทะเลเหล่านี้ เพื่อที่จะได้ทราบขอบเขตอำนาจอธิปไตย และ เขตอำนาจรัฐซึ่งเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ กับ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการทรัพยากรในเขตทะเลหลวง เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักมรดกของมวลมนุษยชาติ

ทะเลอาณาเขตเป็นทะเลส่วนที่ประชิดชายฝั่งโดยอยู่ถัดออกมาจากน่านน้ำภายในและมีความกว้างออกไปในทะเลได้ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน การขยายอาณาเขตทางทะเลของรัฐต่าง ๆ เริ่มทำกันอย่าง

จริงจังกายหลังที่สงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นลง ด้วยเหตุผลที่ต้องการอ้างสิทธิในบริเวณต่างๆ ของทะเลและ
 สงวนไว้ให้คนในชาติ ซึ่งทรัพยากรในบริเวณทะเลที่ประชิดชายฝั่ง โดยที่รัฐต่างๆ มักจะทำคำประกาศฝ่ายเดียว
 เพื่ออ้างสิทธิครอบครองในบริเวณชายฝั่งรวมทั้งทรัพยากรในบริเวณดังกล่าว รัฐมีอำนาจอธิปไตยในบริเวณ
 ทะเลอาณาเขต ทั้งนี้รวมถึงห้วงอากาศเหนือทะเลอาณาเขตและพื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดินของบริเวณนี้ด้วย
 ในบริเวณเขตต่อเนื่องซึ่งมีระยะห่างจากฝั่งไม่เกิน 24 ไมล์จากเส้นฐาน รัฐชายฝั่งมีอำนาจควบคุมและป้องกันมิ
 ให้เกิดการละเมิด รัฐชายฝั่งช่องแคบไม่ว่ารัฐเดียวหรือ 2 รัฐขึ้นไป มีอำนาจและสิทธิเหนือบริเวณช่องแคบที่ติด
 กับชายฝั่งของตน แต่ไม่มีสิทธิในการขัดขวางการใช้สิทธิในการผ่านช่องแคบของรัฐอื่นๆ เพื่อการคมนาคมระหว่าง
 ประเทศ ส่วนรัฐหมู่เกาะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับรัฐชายฝั่งในการขยายอาณาเขตทางทะเล เขตประมงเป็น
 อาณาเขตในทะเลที่อำนวยการประมงให้แก่อำนาจรัฐชายฝั่งในด้านประมงมานานแต่ในปัจจุบันนี้ได้ลดความสำคัญลง
 ไปมากนับแต่ได้มีแนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะ สำหรับเขตเศรษฐกิจจำเพาะเป็นบริเวณอาณาเขตทางทะเล
 ของรัฐชายฝั่ง ซึ่งขยายออกไปเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของรัฐชายฝั่งเป็นสำคัญ โดยเฉพาะรัฐที่มีสภาพทาง
 เศรษฐกิจที่จำเป็นต้องพึ่งพาการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลบริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่

เป็นคำถามปลายเปิดที่สามารถอธิบายได้อย่างกว้างขวางแต่ต้องมีหลักกฎหมายรองรับ

วินิจฉัย

เมื่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 มีสถานะเป็นสนธิสัญญาที่ได้รวบรวม
 ประมวลกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาประมวลลงในอนุสัญญานับดังกล่าว ดังนั้น ทุกรัฐสมาชิก
 ต้องอนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล อีกทั้งรัฐที่ไม่เป็นสมาชิกก็ต้องผูกพันด้วยในฐานะที่ผูกพัน
 ตามอนุสัญญากฎหมายทะเลในฐานะที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ดังนั้น ไม่ว่าประเทศไทย
 จะเป็น หรือ ไม่เป็นภาคีสมาชิกก็ยังคงเคารพในหลักเกณฑ์ของกฎหมายทะเลดังกล่าว และ เคารพในหลัก
 เกณฑ์การกำหนดทะเลอาณาเขต และ เขตทางทะเลดังกล่าว จะไปละเมิดเขตทางทะเลของประเทศอื่นๆ ไม่ได้
 จึงเป็นการสมควรที่ประเทศไทยควรจะเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และผลของ
 การเป็นสมาชิกประเทศไทยก็จะต้องมีการออกกฎหมายอนุวัติการตามสนธิสัญญาด้วยเกี่ยวกับเขตทางทะเล อีกทั้ง
 ทั้งต้องเคารพต่อเขตทางทะเลของประเทศอื่นๆ ด้วย อีกทั้งได้รับการเคารพในเขตทางทะเลและการนำข้อพิพาท
 ทางทะเลขึ้นสู่การพิจารณาของศาลกฎหมายทะเล อีกด้วย

สรุป

1. อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) มีสถานะทางกฎหมายเป็นสนธิสัญญา ซึ่งประมวลมาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

2. หากประเทศไทยเป็นสมาชิกต้องอนุวัติการตามหลักกฎหมายภายใต้อนุสัญญาฉบับดังกล่าวตามหลักกฎหมายสนธิสัญญา แม้ไม่เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญานี้ ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์แห่งกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล

3. ประเทศไทยต้องผูกพันตามผลของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) โดยเฉพาะเกี่ยวกับเขตทางทะเลตามอนุสัญญาฉบับนี้ เช่นจะไปทำการประมงในเขตทางทะเลของประเทศอื่นๆไม่ได้ ขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะได้รับการเคารพในเขตทางทะเลของตนจากประเทศอื่นๆ ตลอดจนการเจรจากำหนดเขตทางทะเลที่มีข้อพิพาทภายใต้กลไกของอนุสัญญาฉบับนี้ และการได้รับการยุติข้อพิพาทภายใต้กลไกและศาลเกี่ยวกับกฎหมายทะเลได้

4. ดังนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาฉบับนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ ที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ ขณะเดียวกันก็ต้องอนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลฉบับนี้ด้วย และการไม่เข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศไทยก็ยังคงต้องยอมรับในหลักการดังกล่าวแต่หากไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกอาจมีความยากลำบากในการใช้สิทธิในการได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้

วิเคราะห์

ข้อสอบในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ กฎหมายสนธิสัญญา และกฎหมายทะเล ซึ่งเป็นความรู้ทั่วไป และ ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนแล้ว หากนักศึกษาได้ อ่าน และ ทำการศึกษา มาอย่างดีแล้วย่อมสามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้เป็นอย่างดี ปัญหาในการทำข้อสอบของนักศึกษา ส่วนใหญ่จึงเกิดจากการไม่ได้ศึกษามาโดยละเอียด และตอบคำถามไม่ครบถ้วน

ข้อ 2. นักศึกษาจงอธิบายวิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีว่ามีกี่วิธี แต่ละวิธีมีกลไกในการระงับข้อพิพาทอย่างไร และ นักศึกษามีความเห็นอย่างไรในการที่รัฐต่างๆได้นำกลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution ADR) เช่น กลไกการยุติข้อพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) มาใช้เพื่อการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกชน ไม่ว่าบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลนั้นไม่มีฐานะเป็นบุคคลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

คำตอบ

ประเด็นปัญหา

1. วิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีว่ามีกี่วิธี แต่ละวิธีมีกลไกในการระงับข้อพิพาทอย่างไร
2. กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution - ADR) เช่น กลไกการยุติข้อพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) มาใช้เพื่อการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน มีปัญหาในทางปฏิบัติอย่างไร ซึ่งนักศึกษาสามารถมีความเห็นปลายเปิดได้ โดยวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย

หลักกฎหมาย

1. อธิบายวิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี ซึ่งจำแนกเป็น

1. การระงับข้อพิพาททางการเมือง
2. การระงับข้อพิพาททางการศาล

นักศึกษาอธิบายวิธีการและกลไกในการระงับข้อพิพาททั้งสองประเภทโดยสังเขป

2. การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐ

วิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีที่สำคัญทางการเมืองมี 4 วิธี แต่ละวิธีมีกลไกในการระงับข้อพิพาทดังต่อไปนี้

1. การเจรจาทางการทูต (Negotiation)

1. พันธกรณีในการเจรจามีมูลฐานมาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ รัฐอาจยืนยันหรือระบายละเอียดของพันธกรณีดังกล่าวในสนธิสัญญาต่างๆ เช่น อาชญากรรมให้ใช้การเจรจาสำหรับการระงับข้อพิพาทในบางเรื่อง ตัวอย่างเช่น อนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1979 ว่าด้วยมลพิษข้ามแดนทางอากาศและความตกลงต่าง ๆ ว่าด้วยการต่อต้านมลพิษทางทะเลที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือระบุเป็นวิธีการเพื่อการแสวงประโยชน์จากแหล่งขุดเจาะทรัพยากรใกล้เขตเส้นสุดเขตไหล่ทวีป ตามอนุสัญญากรุงสตอกโฮล์ม ค.ศ. 1972 ระหว่างฟินแลนด์กับสหภาพโซเวียตรัสเซีย เป็นต้น

2. หน้าที่ในทุกสถานการณ์ในการเจรจาเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐที่พิพาทกันโดยไม่จำเป็นต้องมีการระบุไว้ในตัวบทใด การเจรจามักเป็นกระบวนการเริ่มต้นของกระบวนการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นหรือมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกต่อกระบวนการอื่น คำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศยืนยันว่าก่อนที่จะใช้วิธีการทางการศาล วัตถุประสงค์ของข้อพิพาทต้องถูกนิยามให้ชัดเจนด้วยวิธีการเจรจาทางการทูต

3. ผลของพันธกรณีในการเจรจามีหลายระดับ ขั้นต่ำสุดคือ หน้าที่ในการเริ่มการเจรจาเพื่อหาทางบรรลุข้อยุติ ขั้นต่อมาก็คือ ต้องทำการเจรจาอย่างสุจริตใจ กล่าวคือมิใช่เพียงการยื่นกรานในหลักการที่เป็นคุณแก่ตนเท่านั้น แต่ต้องพยายามใช้หลักแห่งความเที่ยงธรรมด้วย โดยดำเนินการให้การเจรจามีความหมายหรืออีกนัยหนึ่งก็คือต้องพยายามอย่างจริงจังหรือโดยสุจริตใจที่จะเจรจาให้สำเร็จ โดยคำนึงถึงเหตุผลและข้อโต้แย้งของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยซึ่งหมายความว่า การที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอ ข้อโต้แย้งหรือเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมีเหตุผลอันสมควร อย่างไรก็ตามในหลักการกฎหมายมิได้กำหนดให้ฝ่ายที่พิพาทกันต้องบรรลุข้อยุติแต่อย่างใด เว้นแต่จะกำหนดขึ้นตามสนธิสัญญา เช่น พันธะที่กำหนดขึ้นในสนธิสัญญาให้รัฐที่สืบลิทธิทำการเจรจาเพื่อทำสนธิสัญญาที่เคยผูกพันรัฐเดิมก่อนที่จะตนจะได้รับเอกราช

4. วิธีการในการเจรจา การเจรจาอาจเกิดขึ้นแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ได้ที่สำคัญก็คือเป็นการสนทนาที่นำไปสู่การยอมรับข้อยุติร่วมกันซึ่งมักทำกันในรูปของการทำสนธิสัญญา หรือในกรณีตรงกันข้ามก็คือการยืนยันความล้มเหลวของความพยายามหาข้อยุติในการพิพาทอย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ของการ

เจรจามีใช้การเฉพาะการระงับข้อพิพาทแต่อาจรวมถึงการป้องกันหรือการปลดชนวนสถานการณ์ที่มีศักยภาพเป็นข้อพิพาทได้ ผู้ที่ทำการเจรจามีคุณลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย โดยอาจเป็นนักการเมือง ประมุขของรัฐ หรือรัฐบาล รัฐมนตรี หรืออาจถูกมอบหมายให้ผู้แทนพิเศษของรัฐ นักการทูต และหากข้อพิพาทเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ อาจจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐอื่นที่มีฝ่ายที่พิพาทกันเพื่อทำการเจรจาในรูปของที่ประชุมหรือการประชุมแบบรัฐสภาซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือ สำหรับข้อดีทำให้อาจติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และลักษณะที่ไม่เป็นความลับระหว่างฝ่ายที่พิพาทกันทำให้เอื้อต่อการผ่อนปรนท่าทีแต่ในทางกลับกันก็อาจมีผลเสียในแง่ที่มติดินทางภายในประเทศอาจกดดันมิให้รัฐบาลของตนใช้ท่าทีอะลุ่มอล่วย

2. การยุติข้อพิพาทโดยการเข้าร่วมโดยบุคคลที่ 3 ซึ่งมีฝ่ายในข้อพิพาท

การเข้าร่วมมีด้วยกันหลายวิธี โดยอาจแบ่งได้ตามเกณฑ์ของบทบาทของบุคคลที่สาม หรือระดับของการจัดตั้งเป็นหน่วยงาน ตามเกณฑ์แรก ต้องคำนึงถึงบทบาทว่าบุคคลที่สามเข้าร่วมในการเจรจาปัญหาหรือไม่ ส่วนเกณฑ์ที่สองนั้นพิจารณาจากลักษณะของบุคคลที่สามว่าเป็นปัจเจกชนหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้น

การเข้ามีส่วนร่วมของบุคคลที่สามมิได้มุ่งเพียงแค่การอำนวยความสะดวกในการเจรจา แต่อาจมีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาความตึงเครียดของสถานการณ์เพื่อเตรียมเงื่อนไขในการเปิดการเจรจาต่อไป รวมไปถึงการช่วยประกันการปฏิบัติตามข้อยุติที่ตกลงกันได้ด้วย

2.1 การจัดเจรจา เป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่มีการทำประมวลไว้ในอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1899 และ ค.ศ. 1907 การจัดเจรจา เป็นการเข้าร่วมของรัฐที่สามที่เห็นเหมาะสมที่เสนอตัวเข้าช่วยในการแก้ไขปัญหาพิพาท หรือที่ได้รับเชิญเพื่อการนี้ อันเป็นการเข้าร่วมในระดับต่ำสุดของการระงับข้อพิพาท โดยบุคคลที่สามนี้จะใช้อิทธิพลทางการเมืองหรือทางจิตใจเพื่อสร้างหรือฟื้นฟูการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่พิพาทกันและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดให้มีการเจรจาระหว่างรัฐดังกล่าว โดยหลักการแล้วรัฐที่สามจะไม่เข้าร่วมโดยตรงในการเจรจา ภารกิจจะยุติลงเมื่อรัฐฝ่ายต่างๆ ที่พิพาทยอมรับที่จะร่วมหารือและเริ่มการเจรจา ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาได้จัดให้มีการเจรจาเมื่อ ค.ศ. 1946 ระหว่างฝรั่งเศสที่ดำเนินการในนามของเขมรที่อยู่ในอารักขาของตนกับไทย เพื่อหาข้อยุติสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับพรมแดน และในทำนองเดียวกัน ฝรั่งเศสได้จัดให้มีการเจรจาอันนำไปสู่ความตกลงซึ่งมีเป้าหมายในการยุติสงครามอินโดจีน ณ กรุงปารีส ค.ศ. 1973 หรือการที่ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสดำเนินการชักชวนอย่างลับๆ ให้รัฐบาลผสมเขมรสามฝ่ายซึ่งประกอบด้วยฝ่ายเจ้าสีหนุ ฝ่ายนายซอนซานและฝ่ายเขมรแดงของพอลพตและเขี้ยวสัมพันธ์กับฝ่ายนายเฮงสัมรินเปิดการเจรจากันโดยให้ใช้กรุงเทพฯ หรือกรุงปารีสในฐานะดินแดนที่เป็นกลางเป็นสถานที่ในการเจรจากัน เป็นต้น

2.2 การไกล่เกลี่ย เป็นการจัดให้มีการเจรจาระหว่างรัฐฝ่ายที่พิพาทกัน โดยผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะเสนอพื้นฐานของการเจรจาและมีส่วนในการดำเนินการเจรจาด้วย เพื่อผลักดันให้มีการประสานงานมุมมองของรัฐที่พิพาทกัน ตัวอย่างเช่น อังกฤษได้ทำการไกล่เกลี่ย เมื่อ ค.ศ. 1867 ข้อพิพาทระหว่างฝรั่งเศสกับปรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องลักเซมเบิร์ก สหรัฐอเมริกาก็ทำหน้าที่ดังกล่าวในกรณีพิพาทระหว่างรัสเซีย

กับญี่ปุ่น เมื่อ ค.ศ. 1905 และได้ใกล้เคียงข้อพิพาทระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์จนทำให้เกิดการทำความตกลงที่แคมป์เดวิด ค.ศ. 1978 และสนธิสัญญาสันติภาพ ค.ศ. 1979 ตามลำดับ เช่นเดียวกับอัลจีเรียที่ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเรื่องการจับนักการทูตอเมริกันเป็นตัวประกันจนบรรลุข้อตกลงกรุงอัลเจียร์ ค.ศ. 1981 รวมทั้งกรณีการจัดการเจรจาโดยสหรัฐอเมริกากับนอร์เวย์ที่นำไปสู่ความตกลงกรุงวอชิงตัน ค.ศ. 1993 ระหว่างอิสราเอลกับขบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์ทางปฏิบัติ การจัดการเจรจาและการไกล่เกลี่ยถูกมอบหมายให้ผู้แทนของรัฐที่สามซึ่งส่วนมากมักจะเป็นรัฐมหาอำนาจหรือ บุคคลที่เป็นเอกเทศมิได้อยู่ในฐานะผู้แทนของรัฐ หรือผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศที่มีใช้ระดับรัฐบาลเช่นของคณะกรรมการกาชาดสากล การปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีนี้อาจเป็นผลงานของปัจเจกชนหรือกลุ่มบุคคล ก็ได้

การระงับข้อพิพาทวิธีนี้แตกต่างจากการเจรจาตรงที่มีบุคคลหรือฝ่ายที่สามเข้ามาช่วย ทำให้คู่พิพาทมีโอกาสได้เจรจากันและทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างคู่พิพาทที่ไม่ยอมติดต่อกันโดยตรง โดยผู้ไกล่เกลี่ยอาจทำการเจรจากับคู่พิพาทแต่ละฝ่ายสลับกันไปเพื่อให้ตกลงยอมรับข้อเสนอล่าสุดท้ายของคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง ที่เรียกว่าการทูตแบบที่ผู้ไกล่เกลี่ยต้องติดต่อกลับไปกลับมาระหว่างคู่พิพาทฝ่ายต่างๆ (shuttle diplomacy) เช่นที่สหรัฐอเมริกาทำอยู่ขณะนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลาง ผู้ไกล่เกลี่ยจะเข้าร่วมในการเจรจาโดยทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและพยายามประสานท่าทีและข้อเรียกร้องที่แตกต่างหรือตรงข้ามกันของฝ่ายที่พิพาทกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ โดยเสนอทางออกให้และสำรวจช่องทางที่จะทำให้ฝ่ายที่พิพาทกันสามารถตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกัน

ลักษณะสำคัญของการไกล่เกลี่ยคือ จะต้องกระทำอย่างเงียบๆ และแนบเนียนมิให้เกิดการเสียหน้าขึ้น ผู้ไกล่เกลี่ยทำได้เพียงให้คำแนะนำเท่านั้น โดยข้อไกล่เกลี่ยไม่มีผลบังคับตามกฎหมายสำหรับคู่พิพาทที่จะต้องถือปฏิบัติตาม การไกล่เกลี่ยจะกระทำได้ก็ด้วยความยินยอมของคู่พิพาทเท่านั้น และการเสนอตัวเข้ามาไกล่เกลี่ยไม่ถือเป็นการสอดแทรกเข้ามายุ่งเกี่ยวในกิจการภายในของรัฐและไม่เป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตร คุณสมบัติสำคัญของผู้ไกล่เกลี่ยคือต้องมีความเป็นกลางและมีสถานะพิเศษซึ่งทำให้เป็นที่เกรงใจของฝ่ายต่างๆ ที่พิพาทกันอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การไกล่เกลี่ยมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้การไกล่เกลี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายที่พิพาทกันตกลงหาข้อยุติได้หรือเมื่อผู้ไกล่เกลี่ยตระหนักดีว่าการไกล่เกลี่ยของตนไม่อาจประสบผลสำเร็จได้

การจัดการเจรจาหรือการไกล่เกลี่ยอาจนำไปสู่การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการที่มีผลบังคับได้ เช่น การที่ฝรั่งเศสดำเนินการจนมีการทำข้อตกลงให้ใช้อินญูอาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยเหนือเกาะฮามิช ระหว่างเยเมนกับอิริเทรีย เมื่อ ค.ศ. 1996 ฯลฯ

2.3 การสืบสวนหาข้อเท็จจริง

ลักษณะ เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงอันเป็นต้นกำเนิดของการพิพาทเพื่อยืนยันรายละเอียดของเหตุการณ์และลักษณะของข้อพิพาทตลอดจนสภาพการณ์แวดล้อมต่างๆ และนำเสนอต่อฝ่ายที่พิพาทกันในรูปของรายงาน ซึ่งโดยธรรมดาแล้วจะถูกมอบหมายให้คณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในรูปองค์กรที่เรียกกันว่า

คณะกรรมการการสืบสวนหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งความตกลงระหว่างรัฐที่พิพาทกันโดยได้มีการกำหนดภารกิจกล่าวคือ ระบุข้อเท็จจริงซึ่งต้องทำการพิจารณา วิธีการจัดตั้งองค์คณะ กำหนดเวลาในการจัดตั้ง ตลอดจนขอบเขตของอำนาจ

แม้วิธีการนี้จะมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด หรือแม้แต่เพื่อเสนอทางออกสำหรับปัญหาที่พิพาทกัน แต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่สำคัญมากประการหนึ่งเพราะมีข้อพิพาทจำนวนมากที่มีสาเหตุมาจากความเห็นขัดแย้งในเรื่องข้อเท็จจริงซึ่งหากฟังเป็นยุติได้ทางใดทางหนึ่งก็อาจวินิจฉัยได้ ตัวอย่างเช่น ปัญหาการประมงระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านซึ่งมักเกิดจากความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องข้อเท็จจริงว่าเรือประมงไทยได้ลักลอบเข้าทำการประมงในน่านน้ำของประเทศเพื่อนบ้านจริงหรือไม่ หรือเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนซึ่งหากสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้เถียงกันให้แน่ชัดได้ ในบางกรณีก็อาจนำไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเด็ดขาดได้ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียบริเวณศาลเจ้าเป้งกงหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าศาลเจ้าฮกเติกที่ยังโต้เถียงกันอยู่ว่าอยู่ในเขตแดนไทยหรือมาเลเซีย ในเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับเป็นหลักการว่าให้ถือเอาสันปันน้ำเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขตแดนบริเวณนี้ หากตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏแน่ชัดว่าศาลเจ้าดังกล่าวอยู่ด้านไหนของสันปันน้ำ ก็ย่อมตัดสินได้ทันทีว่าศาลเจ้านั้นอยู่ในดินแดนของประเทศใด ซึ่งในกรณีนี้ผลของการระงับข้อพิพาทด้วยการสืบสวนหาข้อเท็จจริงก็จะใกล้เคียงกับผลของการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ เพราะแม้ว่าผลของการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ผูกพันให้รัฐฝ่ายต่างๆ ที่พิพาทกันต้องยอมรับและดำเนินการต่อไปก็ตาม แต่การที่คณะกรรมการการสืบสวนฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าเป็นคุณแก่ฝ่ายใดแล้ว ก็ย่อมทำให้เกิดความชอบธรรมแก่ฝ่ายนั้นในสายตาของมหาชนระหว่างประเทศขึ้น

อย่างไรก็ดี รายงานของคณะกรรมการไม่มีผลบังคับ และคณะกรรมการไม่มีหน้าที่ในการสรุปผลอันสืบเนื่องจากการสืบสวนแต่อย่างใด ลักษณะดังกล่าวของการสืบสวนหาข้อเท็จจริงทำให้การสืบสวนหาข้อเท็จจริงมิใช่วิธีการระงับข้อพิพาทในตัวเอง แต่ต้องใช้ประกอบกับการเจรจาหรือวิธีการระงับข้อพิพาททางการศาลอื่น ๆ

ยิ่งกว่านั้นประสิทธิภาพของการสืบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับการดำเนินการโดยทันทีหลังเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความขัดแย้ง แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น จึงมีสนธิสัญญาหลายฉบับซึ่งพยายามปรับปรุงกลไกและพัฒนาประสิทธิภาพของวิธีการนี้

มูลฐานทางสนธิสัญญาและทางปฏิบัติ วิธีการนี้ถูกกำหนดขึ้นในอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1899 โดยความริเริ่มของชาวรัสเซียชื่อ de Martens และได้รับการยืนยันในอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1907 หลังจากนั้นก็ถูกกำหนดให้เป็นวิธีการที่ต้องใช้เมื่อมีการระบุให้ใช้อนุญาโตตุลาการภาคบังคับในสนธิสัญญา ค.ศ. 1909 ระหว่างสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและอังกฤษ และในอนุสัญญาต่อมาซึ่งขยายเขตอำนาจให้พิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายด้วย และแม้แต่ในพิธีสาร ค.ศ. 1977 ต่อท้ายอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1949 มาตรา 90 ว่าด้วยกฎหมายมนุษยธรรม ก็กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของอนุสัญญา

อย่างไรก็ดี ในภาพรวมแล้ววิธีการนี้มีได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเท่าที่ควรในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ข้อจำกัดของการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีนี้อยู่ที่ว่าฝ่ายที่พิพาทต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา อีกทั้งหากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของรัฐฝ่ายที่พิพาทกัน รัฐเหล่านั้นจะเลือกใช้วิธีนี้ก็ต่อเมื่อมั่นใจในข้อเท็จจริงของฝ่ายตนและมีความจริงใจที่จะหาข้อยุติให้ได้เท่านั้น มิฉะนั้นย่อมเป็นการเสี่ยงเกินไปที่อาจตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หากข้อค้นพบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่ตนอ้าง

2.4 การประนีประนอมระหว่างประเทศ

นิยาม ลักษณะและผลทางกฎหมายการประนีประนอม เป็นการพิจารณาข้อพิพาทโดยองค์การที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยความยินยอมของรัฐฝ่ายที่พิพาทกัน องค์การประนีประนอมจะเสนอข้อยุติให้กับรัฐที่พิพาทกันเพื่อให้นำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป การใช้วิธีการนี้ขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างรัฐฝ่ายที่พิพาทกันเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ว่าล่วงหน้าก่อนหรือหลังการเกิดขึ้นของข้อพิพาทก็ตาม ดังนั้น กระบวนการต่างๆ ของวิธีการนี้อาจมีความแตกต่างกันออกไป แต่ลักษณะร่วมกันก็พอจะสรุปได้ ดังนี้ ตามมาตรา 15 ของกรรมการทั่วไปแห่งการอนุญาโตตุลาการ ค.ศ. 1928 กรรมการการประนีประนอมมีหน้าที่ในการให้ความกระจ่างต่อปัญหาต่างๆ ในข้อพิพาท รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้โดยอาศัยการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือวิธีการอื่น ตลอดจนในการพยายามประนีประนอมรัฐฝ่ายต่างๆ ที่พิพาทกัน หลังจากการพิจารณาแล้วคณะกรรมการการประนีประนอมอาจเสนอข้อยุติหรือความตกลงให้ฝ่ายที่พิพาทกันพิจารณา การประนีประนอมแตกต่างจากการไกล่เกลี่ยตรงที่คณะกรรมการการประนีประนอมต้องเสนอทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จากการไต่สวนและโดยวิธีอื่นๆ ให้คู่พิพาทพิจารณาด้วย ซึ่งทำให้ในแง่หน้าที่ของคณะกรรมการการประนีประนอมจะคล้ายกับหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการ ส่วนข้อแตกต่างอยู่ที่ข้อเสนอของคณะกรรมการการประนีประนอมมิได้มีผลบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใด

การดำเนินการ วิธีการนี้ถือว่าน่าพอใจหากพิจารณาการกำหนดวิธีการไว้ในสนธิสัญญาต่างๆ เช่น ในมาตรา 42 ของกติกา ค.ศ. 1966 ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง มาตรา 284 และภาคผนวกที่ 5 ของอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ฯลฯ แต่ในทางปฏิบัติ จำนวนการใช้วิธีการประนีประนอมก็ยังค่อนข้างจำกัด เนื่องจากหากฝ่ายที่พิพาทกันขาดความมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะก็มักจะไม่น่าเสี่ยงใช้วิธีการดังกล่าวซึ่งอาจก่อให้เกิดความกดดันทางการเมืองตามมาได้ เพราะรายงานของคณะกรรมการการประนีประนอม แสดงว่าในสายตาของผู้เป็นกลาง ข้อเสนอเป็นทางออกที่เป็นธรรม ดังนั้น ฝ่ายที่ยอมรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประนีประนอมย่อมเป็นฝ่ายที่มีความชอบธรรมในสายตาของมหาชนระหว่างประเทศ ทั้งนี้โดยอาจอ้างถึงตัวอย่างที่สำคัญ เช่น ในกรณีการพิพาทด้านดินแดนระหว่างเยอรมนีกับการอารักขาของฝรั่งเศสกับไทยเมื่อ ค.ศ. 1947 ที่ฝรั่งเศสเรียกร้องให้ไทยคืนดินแดน 4 จังหวัด อันได้แก่ เสียมราชู พระตะบอง ศรีโสภณ และศรีสะเกษ ซึ่งฝรั่งเศสต้องยอมยกให้ไทยในกรณีพิพาทกับประเทศไทย เพราะไม่สามารถฝ่าฝืนอิทธิพลของญี่ปุ่นซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ในขณะนั้น โดยฝรั่งเศสได้เสนอข้อพิพาท

ดังกล่าวให้คณะกรรมการการประนีประนอมที่ตั้งขึ้นตามข้อตกลง ค.ศ. 1946 ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส คณะกรรมการการประนีประนอมดังกล่าวได้เสนอแนะว่า ให้ดินแดนทั้ง 4 จังหวัดนั้นกลับคืนสู่สถานะเดิม (Status quo ante) กล่าวคือกลับไปเป็นของฝรั่งเศสตามเดิม ซึ่งแม้ว่าโดยหลักการแล้วข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประนีประนอมจะไม่มีผลบังคับตามกฎหมายให้รัฐคู่พิพาทต้องยอมถือปฏิบัติตาม แต่ไทยก็ไม่อาจฝืนแรงกดดันได้และต้องยอมคืนดินแดนที่เคยเสียไปในสมัยอาณานิคมให้ฝรั่งเศสไปในที่สุด

ส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งคือ ความตกลง ค.ศ. 1980 คณะกรรมการการประนีประนอมได้แบ่งเขตไหล่ทวีประหว่างไอซ์แลนด์กับเกาะชือ ยัน มาเยน ของนอร์เวย์ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลง กรุงออสโลว์ ค.ศ. 1981 เกี่ยวกับการแสวงประโยชน์ที่เที่ยงธรรมจากทรัพยากรในไหล่ทวีปดังกล่าว

3. การอนุญาโตตุลาการ

ลักษณะสำคัญของการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการคือ การที่รัฐฝ่ายต่างๆ ที่พิพาทกันมีสิทธิในการคัดสรรตุลาการเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ตัดสินชี้ขาดปัญหาพิพาทที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณารวมทั้งกฎหมายและกระบวนการพิจารณาสำหรับคดีของตนเองได้ การอนุญาโตตุลาการมีลักษณะดังนี้

1. ลักษณะของความสมัครใจที่จะใช้อนุญาโตตุลาการ วิธีการดังกล่าวเป็นผลของความยินยอมของรัฐฝ่ายที่พิพาทกัน โดยการแสดงความยินยอมต้องมีลักษณะที่ชัดเจนและแน่นอนที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศขึ้นอย่างแท้จริง
2. อนุญาโตตุลาการจากการเลือกของฝ่ายที่พิพาทกัน ความตกลงใช้การอนุญาโตตุลาการ ความตกลงที่กระทำกันโดยสนธิสัญญาเรียกว่า ข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการ (Compromis) ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายสนธิสัญญา ส่วนการมีผลใช้บังคับก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายภายในเรื่องการทำสนธิสัญญา ฝ่ายที่พิพาทกันอาจกำหนดเนื้อหาของข้อตกลงได้อย่างเสรีซึ่งอาจแตกต่างออกไปจากกฎเกณฑ์ทั่วไปของอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการ เพราะฉะนั้นข้อตกลงจึงถือเป็นกฎหมายของการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมักประกอบด้วย การนิยามวัตถุประสงค์ของการพิพาท กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา กฎหมายที่ใช้บังคับ หากมีช่องโหว่ทางเทคนิคในกรณีที่ฝ่ายที่พิพาทกันเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการก็ย่อมไม่ประสบปัญหายุ่งยากนัก เพราะประเด็นที่เป็นช่องโหว่ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ทั่วไปของอนุสัญญา แต่วิธีที่รอบคอบที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวก็คือการตั้งกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญขึ้นเพื่อทำการร่างข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการ

3. รูปแบบของการแสดงเจตนาให้ใช้อนุญาโตตุลาการภาคบังคับ อนุญาโตตุลาการประเภทนี้เกิดจากการยอมรับล่วงหน้าก่อนจะมีข้อพิพาท อันเป็นผลจากการเจรจาทางการทูต และทำให้สามารถเริ่มกระบวนการได้โดยการกระทำฝ่ายเดียวของฝ่ายที่พิพาทกัน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้ว ก็มักจะมีการทำข้อตกลงแห่งการอนุญาโตตุลาการขึ้นเพื่อระบุกระบวนการและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน รวมไปถึงเพื่อการยืนยันลักษณะบังคับของการอนุญาโตตุลาการด้วยเพื่อตัดข้อสงสัยใดๆ การยอมรับวิธีการนี้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอใน

ศตวรรษที่ 20 ทั้งโดยอาศัยสนธิสัญญาทวิภาคีและพหุภาคี ในระดับสากลและระดับภูมิภาค

4. เทคนิคของข้อบทกำหนดการอนุญาโตตุลาการ (Compromissory clause) เป็นการระบุเจตนายินยอมให้มีการอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อบทของสนธิสัญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มีใช้เพื่อการอนุญาโตตุลาการเป็นการเฉพาะ ข้อบทเช่นนี้มักปรากฏในข้อบทสุดท้ายของสนธิสัญญา โดยมีผลทางกฎหมายที่แตกต่างกันออกไป ในกรณีที่กำหนดให้ใช้การอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้และการตีความสนธิสัญญาที่ระบุข้อบทดังกล่าวจะเรียกกันว่า “ข้อบทพิเศษ” ซึ่งมักพบกันมากในสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยสันติภาพ การค้า การขนส่งทางอากาศ สวัสดิการสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเพื่อนบ้าน ส่วนในสนธิสัญญาพหุภาคีจะพบเฉพาะในสนธิสัญญาเกี่ยวกับการคมนาคมระหว่างประเทศเท่านั้น เช่น เรื่องการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ แต่เมื่อข้อบทมุ่งที่จะให้ใช้อนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาททุกประเภทที่เกิดจากสนธิสัญญาที่ระบุข้อบทดังกล่าวนี้ จะเรียกว่าเป็น “ข้อบททั่วไป” ตัวอย่างเช่น ข้อบทของมาตรา 9 แห่งอนุสัญญา ค.ศ. 1952 ซึ่งยุติระบอบการยึดครองสหพันธรัฐเยอรมนีโดยสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส ยิ่งกว่านั้นในสนธิสัญญาฉบับเดียวกันอาจมีการบัญญัติข้อบททั้งสองประเภทไว้ด้วยกัน เช่น ในสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนต่างชาติ กล่าวคือใช้ข้อบทพิเศษสำหรับข้อพิพาทระดับรัฐบาล และข้อบททั่วไปสำหรับข้อพิพาทระหว่างรัฐผู้รับการลงทุนกับนักลงทุนเอกชนต่างชาติ

5. เทคนิคของการทำสนธิสัญญาแห่งการอนุญาโตตุลาการ การแสดงเจตนาในสนธิสัญญาที่มุ่งให้มีการใช้อนุญาโตตุลาการมีผลทางกฎหมายที่กว้างกว่าโดยเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่มีลักษณะกว้างกว่าเทคนิคก่อนหน้านี้ ส่วนมากเป็นผลของสนธิสัญญาทวิภาคี

6. ขอบเขตการใช้ของการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการอาจใช้ได้กับข้อพิพาททุกประเภทซึ่งฝ่ายที่พิพาทกันต้องการ โดยไม่คำนึงถึงเดิมพันของผลประโยชน์ทางการเมืองหรือลักษณะทางเทคนิคของข้อพิพาท ดังนั้น จึงอาจมีการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการเมืองได้ แม้ว่าส่วนใหญ่จะจำกัดขอบเขตของการอนุญาโตตุลาการไว้สำหรับข้อพิพาททางกฎหมายก็ตาม โดยอาจใช้สำนวนอ้างถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการใช้และการตีความสนธิสัญญา หรืออาจจะระบุประเภทข้อพิพาทเป็นการเฉพาะ ในอดีตมีการตั้งข้อสงวนสำหรับการยอมรับให้มีการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างกว้างและขึ้นอยู่กับความดีความชอบของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทำให้ในปัจจุบันถูกยกเลิกไปโดยคงมีเพียงการทำข้อสงวนที่มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เช่น ข้อสงวนที่ตัดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนการให้การยอมรับหรือข้อสงวนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดินแดน รวมทั้งข้อสงวนที่กระทบเขตอำนาจแห่งชาติของรัฐฝ่ายที่พิพาท เป็นต้น

7. องค์การอนุญาโตตุลาการ การจัดตั้งองค์การอนุญาโตตุลาการ โดยหลักแล้วขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของรัฐฝ่ายที่พิพาทกัน ซึ่งจะตกลงกันว่าจะร่วมกันจัดตั้งองค์การอนุญาโตตุลาการขึ้นเอง หรืออาศัยการจัดตั้งโดยบุคคลที่สามเพื่อป้องกันปัญหาในการจัดตั้งองค์กร ตัวอย่างเช่น มาตรา 55 ของอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ 1 และมาตรา 21 ของกรรมสารทั่วไปแห่งอนุญาโตตุลาการ ค.ศ. 1928 รวมทั้งมาตรา 3 ของแบบแห่งกฎเกณฑ์ ค.ศ. 1957 ของคณะกรรมการการกฎหมายระหว่างประเทศ ได้ระบุวิธีการอย่างละเอียดให้บุคคล

ที่สามเข้ามาทำการจัดตั้งองค์กรอนุญาโตตุลาการ โดยมักกำหนดให้เป็นประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือเลขาธิการสหประชาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม หากรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ร่วมมือก็อาจเกิดความยุ่งยากขึ้นได้

8. โครงสร้างขององค์กรอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการ ซึ่งประกอบด้วยตุลาการรายเดียว แม้ในอดีตจะดำเนินการกัน แต่ทางเลือกรูปแบบนี้ถูกจำกัดลงในปัจจุบัน โดยตุลาการมักถูกคัดเลือกจากนักนิติศาสตร์ นักการทูตหรือผู้พิพากษา ตัวอย่างเช่น สมเด็จพระราชินีอังกฤษได้ทำคำชี้ขาด 2 ฉบับในข้อพิพาทด้านพรมแดนระหว่างอาร์เจนตินาและชิลี ค.ศ. 1966 สำหรับพรมแดนแอนดิส และกรณีคลองบีเกิล ค.ศ. 1977 ซึ่งที่จริงแล้วศาลที่ประกอบด้วยนักนิติศาสตร์เป็นผู้ร่างคำชี้ขาดและสมเด็จพระราชินีเป็นผู้รับร่างเป็นคำชี้ขาด คณะกรรมการการผสม มีต้นกำเนิดจากสนธิสัญญาเจย์ ค.ศ. 1974 ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ โดยแต่เดิมมีลักษณะเป็นกรรมการผสมจากตัวแทนของรัฐที่พิพาทกัน ประธานกรรมการ (Umpire) อาจถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อร่วมในการพิจารณาและตัดสินในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างกรรมการผสมจากตัวแทนของรัฐ ศาลที่จัดตั้งเป็นองค์คณะ ในปัจจุบันรัฐฝ่ายต่างๆ ที่พิพาทกันจัดตั้งองค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิก 3-5 ราย ซึ่งประกอบด้วยตุลาการจากรัฐที่พิพาทกันและตุลาการที่เป็นกลาง หรือตุลาการที่เป็นกลางทั้งหมด ก็ได้ องค์คณะเช่นนี้ในทางเทคนิคถือว่าดีที่สุดเนื่องจากประกันความเป็นกลาง ในทางปฏิบัติจำนวนตุลาการจะไม่เกิน 3 คน มิฉะนั้นจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น

9. อำนาจขององค์กรอนุญาโตตุลาการ

1) อำนาจในการกำหนดเขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการ อำนาจขององค์กรเกิดจากข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการ ซึ่งศาลอนุญาโตตุลาการในฐานะองค์กรทางการศาลย่อมมีอำนาจในการตีความได้กล่าวคือ มีอำนาจในการกำหนดเขตอำนาจขององค์กรเพื่อตัดสินปัญหาการโต้แย้งในเรื่องขอบเขตของเขตอำนาจของศาลอนุญาโตตุลาการ

มาตรา 9 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ ได้ทำประมวลจารีตประเพณีในเรื่องนี้ไว้ว่า ศาลอนุญาโตตุลาการตัดสินในเรื่องเขตอำนาจของตน มีอำนาจที่จะตีความข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการและเอกสารอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งเขตอำนาจนั้น แต่การตีความในลักษณะที่ขยายเขตอำนาจอาจถือเป็นการกระทำนอกเขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการ

2) อำนาจในการกำหนดกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่นเดียวกับตุลาการทั้งปวง อนุญาโตตุลาการต้องตัดสินตามกฎหมาย แม้จะปราศจากข้อบ่งชี้ใดๆ เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับ ในทางปฏิบัติข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการมักจะย้อนส่งไปสู่ข้อแตกต่างๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ในกรณีที่มิได้มีการระบุ อนุญาโตตุลาการจะปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศโดยอัตโนมัติ หากข้อตกลงระบุกฎเกณฑ์พิเศษเป็นการเฉพาะ อนุญาโตตุลาการก็ต้องให้ความสำคัญแก่กฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นลำดับแรก

3) อำนาจพิเศษในบางกรณี องค์กรอนุญาโตตุลาการได้รับอำนาจอย่างชัดเจนในการทำข้อยุติที่เป็นผลจากการต่อรองหรือกันบนพื้นฐานแห่งข้อพิจารณาที่มีใช้ทางกฎหมาย อันทำให้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการประนีประนอมภาคบังคับ ดังตัวอย่างในอดีตของข้อพิพาทด้านดินแดน บางครั้งข้อบทพิเศษ

แห่งอนุญาโตตุลาการอาจกำหนดวิธีการระงับแบบ ex aequo et bono เช่นมาตรา 28 ของกรมสารทั่วไป ค.ศ. 1928 ที่บัญญัติให้ตัดสินในกรณีของข้อพิพาทของกฎหมาย

ข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการในกรณียกเว้นอาจให้อนุญาโตตุลาการวางกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่ใช้บังคับในอนาคต โดยมุ่งป้องกันการเกิดขึ้นของข้อพิพาทในทำนองเดียวกันอีกในอนาคต ซึ่งทำให้อนุญาโตตุลาการทำหน้าที่ในแง่นี้เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ข้อบทประเภทนี้เรียกว่า ข้อบทแห่งการระงับข้อพิพาทด้านผลประโยชน์

4. ความพยายามในการจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการ จากการที่ในทางปฏิบัติประสิทธิภาพของอนุญาโตตุลาการมีข้อจำกัด เนื่องจากความยุ่งยากในการจัดตั้งองค์กรอนุญาโตตุลาการที่มีอำนาจกว้างขวางพอที่จะระงับข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างรัฐ ทำให้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในรูปของการประกันการใช้วิธีการดังกล่าวในข้อพิพาทที่สืบเนื่องหรือที่เกิดขึ้นในทำนองเดียวกัน หรือโดยการเสริมผลทางกฎหมายของการยอมรับวิธีการดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรอนุญาโตตุลาการอันทำให้องค์กรมีลักษณะถาวรและทำการพิจารณาคดีได้จากการเรียกร้องฝ่ายเดียวของรัฐ

5. วิธีพิจารณาความ ตามหลักแล้ว วิธีพิจารณาความของอนุญาโตตุลาการจะเป็นไปตามที่รัฐฝ่ายที่พิพาทกันตกลงกันในข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการหรือสนธิสัญญาอื่นใดที่ผูกพันรัฐที่เกี่ยวข้อง หากปราศจากกฎเกณฑ์เหล่านี้ อนุญาโตตุลาการก็มีอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคดี ในปัจจุบันมีการพัฒนามากฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ในอนุสัญญาต่างๆ อันทำให้กระบวนการมีลักษณะคล้ายกับที่ใช้กันในศาล อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อแตกต่างจากวิธีการที่ใช้กันในศาลภายใน โดยเฉพาะในเรื่องที่กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเป็นความลับ (โดยยอมรับให้มีการทำความเห็นแย้งไว้ในคำชี้ขาดได้) เว้นแต่ฝ่ายที่พิพาทกันจะตกลงเป็นอย่างอื่น และการพิจารณาโดยปราศจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นไปได้ยาก

6. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เกิดจากการตัดสินของเสียงส่วนใหญ่ของอนุญาโตตุลาการ คำชี้ขาดไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยการให้เหตุผลเสมอไปเนื่องจากในอดีตเป็นผลงานของประมุขของรัฐซึ่งไม่ประสงค์จะนำประเทศไปพัวพันกับข้อขัดแย้ง แต่ในปัจจุบันรัฐฝ่ายที่พิพาทมักจะกำหนดให้ต้องมีการแสดงเหตุผลไว้ด้วย คำชี้ขาดมีผลบังคับและผูกพันฝ่ายที่พิพาทซึ่งต้องออกมาตรการภายในทั้งปวงที่จำเป็นในการปฏิบัติตามคำชี้ขาด แต่จะมีผลเฉพาะกับรัฐฝ่ายที่พิพาทกันเท่านั้น ส่วนการไม่เคารพผลคำชี้ขาดย่อมก่อให้เกิดความรับผิดชอบของรัฐที่ฝ่าฝืน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วคำชี้ขาดมักจะได้รับการปฏิบัติตามอันเนื่องมาจากความกดดันของประชาคมระหว่างประเทศซึ่งมีต่อรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างของอาร์เจนตินาที่แม้จะปฏิเสธคำชี้ขาด เมื่อ ค.ศ. 1977 ในกรณีพิพาทกับชิลีเรื่องคลองบีเกิล โดยอ้างว่าตุลาการพิจารณานอกคำร้องของตนและใช้เหตุผลที่ขัดกัน ทำให้ต้องมีการไกล่เกลี่ยโดยสำนักวาติกันระหว่างอาร์เจนตินากับศาลอนุญาโตตุลาการ จนนำไปสู่การยอมรับที่จะปฏิบัติตามคำชี้ขาดในที่สุด

7. วิธีการโต้แย้งคำชี้ขาด คำชี้ขาดอาจถูกโต้แย้งได้เช่นเดียวกับคำพิพากษาทั่วไปกล่าวคือ ฝ่ายที่พิพาทกันอาจขอให้ศาลอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดทำการตีความ แต่หากศาลอนุญาโตตุลาการดังกล่าวยุติไปแล้ว ก็ให้ศาลอนุญาโตตุลาการที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นผู้ตีความ นอกจากนี้ยังอาจทำการโต้แย้งเพื่อให้ศาลอนุญาโตตุลาการที่ทำการชี้ขาดแก้ไขคำชี้ขาด เมื่อข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการกำหนดไว้ แต่จะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีการยกอ้างการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ที่ยังไม่เป็นที่ล่วงรู้ในขณะที่มีการทำคำชี้ขาดซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคำชี้ขาด สำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเพื่อให้เปลี่ยนแปลงคำชี้ขาดอาจเกิดขึ้นได้เมื่อพิจารณาคำชี้ขาดในฐานะเป็นนิติกรรมซึ่งความสมบูรณ์ย่อมตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย เพราะฉะนั้นฝ่ายที่พิพาทอาจยกอ้างความไม่สมบูรณ์ขึ้นกล่าวคือ การเป็นโมฆะของข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการ และการใช้อำนาจเกินขอบเขตโดยอนุญาโตตุลาการอันสืบเนื่องจากการไม่เคารพเงื่อนไขในข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการ เช่น การตัดสินปัญหาที่มีได้กำหนดไว้ในข้อตกลง หรือมิได้ใช้กฎหมายที่ระบุให้ใช้บังคับ หรือการละเมิดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคดีแบบของกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการการกฎหมายระหว่างประเทศระบุถึงเหตุที่ทำให้คำชี้ขาดเป็นโมฆะอีกประเภทหนึ่งคือ การทุจริตประพฤติดมิชอบของอนุญาโตตุลาการ

อย่างไรก็ดี หากการยกอ้างเป็นผลจากการยืนยันฝ่ายเดียว ก็ย่อมไม่ผูกพันรัฐคู่ความและย่อมนำไปสู่ข้อพิพาทใหม่ เช่น กรณีของกินีบิสเซาที่ยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เมื่อ ค.ศ. 1987 เพื่อโต้แย้งความสมบูรณ์ของคำชี้ขาด วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 ของศาลอนุญาโตตุลาการในเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างกินีบิสเซากับเซเนกัล

โดยสรุปแล้ว การที่รัฐฝ่ายต่างๆ ที่พิพาทกันสามารถควบคุมได้ทั้งองค์ประกอบของตุลาการและวิธีพิจารณาความด้วย ทำให้ต่างก็มีความมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม และมีต้องกังวลว่าตุลาการอาจมีความลำเอียงด้วยเหตุผลทางการเมืองดังเช่นในระบบของศาลโลกที่การคัดสรรตุลาการต้องคำนึงถึงกลุ่มทางการเมือง ดังนั้น รัฐจึงให้ความไว้วางใจวิธีการนี้มากกว่าการขึ้นศาลโลก และที่สำคัญก็คือรัฐสามารถเลือกตัวตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในเรื่องที่พิพาทกันได้ด้วย เหตุผลทั้งหลายเหล่านี้ทำให้อนุญาโตตุลาการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรกฎหมายระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก แม้จะทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็ตาม

2. กลไกการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ที่นำมาใช้เพื่อการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน มีปัญหาในทางปฏิบัติดังนี้ (นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของกฎหมาย ที่มีเหตุผล)

ปัญหาในทางปฏิบัติของประเทศไทยในการนำกลไกการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาใช้ระหว่างรัฐกับเอกชน โดยมีการทำสนธิสัญญา ความตกลง เปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับคู่ภาคี และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกในการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ โดยมีข้อบกพร่องการคุ้มครองนักลงทุนต่างด้าว และให้สิทธินักลงทุนต่างชาติที่เป็นคู่ภาคี สามารถ ฟ้องรัฐได้ โดยการ นำข้อพิพาทสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการได้ (State Investor dispute settlement) นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงนิวออร์คในการที่มีพันธกิจในการยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำหรับภายในประเทศ สัญญาภาครัฐ หรือ ที่รัฐเป็นคู่

สัญญาจะผ่านการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด และในสัญญาเหล่านั้น จะมีข้อกำหนดให้ยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ทั้งสิ้น ในขณะที่ กฎหมายภายในก็มีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการให้สามารถนำข้อพิพาทสู่การยุติในอนุญาโตตุลาการด้วย และสัญญาทางแพ่งที่ภาครัฐได้ทำกับเอกชนก็ได้มีข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการไว้ทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น รัฐบาลย่อมต้องยอมให้เอกชนดำเนินการขอยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการเหล่านี้ รัฐบาลย่อมต้องปฏิบัติตามโดยผลของการแสดงเจตนารมณ์ผูกพันตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ เมื่อมีเจตน์จำนงค์ในการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแต่แรก และโดยผลผูกพันตามอนุสัญญากรุงนิวยอร์กในการที่รัฐบาลต้องยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 5 นิยามคำว่า สัญญาทางปกครอง ให้หมายถึง

“คำนิยาม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง สัญญาทางปกครอง หมายความว่า สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หากมีข้อพิพาทขึ้นให้นำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครอง แต่ในสัญญา ที่นักลงทุนต่างด้าวทำกับรัฐบาล เช่น การลงทุนในกิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ ได้มีข้อกำหนดให้นำข้อพิพาทที่เกิดขึ้นพิจารณาโดย อนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้โดยอาศัย ความผูกพันภายใต้ สนธิสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ และหลักแห่งการแสดงเจตนา และเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น จะเห็นได้ว่า สัญญาดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนด การยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง ตัดเขตอำนาจศาล กล่าวคือ สัญญาใดที่มีข้อกำหนดให้ยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากคู่พิพาทฝ่ายใดกลับมาข้อพิพาทเสนอสู่การพิจารณา หรือ ฟ้องศาล คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งสามารถต่อสู้ยกข้อกำหนดการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมาตัดเขตอำนาจศาลได้ ตามลักษณะของ กลไกการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ และ ผลของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ แต่ สัญญาการลงทุนโดยได้รับสัมปทานดังกล่าวย่อมมีลักษณะสัญญาทางปกครอง ที่มีรัฐบาลเป็นคู่สัญญา และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะนำขึ้นสู่การยุติข้อพิพาทโดยกลไกอนุญาโตตุลาการ หรือ ต้องนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครอง

เพราะข้อกำหนดในสัญญามีผลบังคับตามหลักสัญญา และ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและ สนธิสัญญาที่รัฐผูกพันกับต่างชาติ แต่ขัดกับกฎหมายภายใน ในพรบ ดังกล่าว การแสดงเจตนาของเอกชน อยู่เหนืออำนาจอธิปไตยทางศาล หรือไม่ กฎหมายภายในขัดกับพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาอันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ หรือไม่ ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีลักษณะอย่างไร หากนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองก็ผิดสัญญา และ ผิดข้อตกลงในสนธิสัญญา อีกทั้ง หากคู่พิพาทอีกฝ่ายยกข้อต่อสู้มาคัดค้าน ด้วยเรื่อง ข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการ ตัดเขตอำนาจศาล จะอ้างได้หรือไม่ การตัดเขตอำนาจศาลนั้นจะอ้างได้แต่ในศาลแพ่ง หรือสามารถอ้างมาตัดเขตอำนาจศาลปกครองได้ด้วย แต่หากนำข้อพิพาทสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ แล้ว รัฐบาลแพ้ ต้องรับผิดชอบโดยคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ และ รัฐบาลไม่ยอมรับผลของคำชี้ขาด คู่พิพาทอีกฝ่าย

จะนำคำชี้ขาดมาฟ้องร้องให้ศาลบังคับให้ได้หรือไม่ โดยผลของอนุสัญญากรุงนิวยอร์ก ที่ผูกพันให้รัฐสมาชิกต้องบังคับการให้เป็นไปตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ และ หากจะฟ้องให้บังคับ ตามคำชี้ขาดจะฟ้องที่ศาลแพ่ง หรือ ศาลปกครอง แต่หากนำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครอง แล้ว นักลงทุนเอกชนต่างชาติ ต่อบัญชีว่ามีข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการ ศาล ปกครองไม่มีเขตอำนาจศาลจะต่อสู้ได้หรือไม่ หากต่อสู้ไม่ได้ นักลงทุนจะเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบในฐานะที่ไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญา ได้หรือไม่ หากในสนธิสัญญาไม่ได้กำหนดชื่อยกเว้นไว้ว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครองที่จะไม่สามารถนำขึ้นสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และรัฐบาลต้องรับผิดชอบหรือไม่ ข้อพิพาทส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับนักลงทุนเอกชนเกือบทั้งหมด หรือทั้งหมดแล้วแต่เป็นประเด็นพิพาทที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะทั้งสิ้น กรณีนี้ หากนักลงทุนเอกชนชนะในคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการก็จะเสียประโยชน์ของชาติ แต่หาก ไม่ปฏิบัติตาม รัฐก็ถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบในเรื่องความรับผิดชอบของรัฐ และ ผิดสัญญา ละเมิดพันธะภายใต้สนธิสัญญา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการกำหนด ขอบเขต ยกเว้นการบังคับใช้อนุญาโตตุลาการ (Carve out Principle) ในกรณีพิพาทกับรัฐที่พิพาทกันด้วยเรื่องประโยชน์สาธารณะ หรือ นโยบายสาธารณะเป็นต้น

สรุป

กลไกการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนั้น สามารถนำมาใช้ได้แต่ต้องมีการแก้ไขโดยมีข้อกำหนด ยกเว้นการนำกลไกดังกล่าวมาใช้ในสนธิสัญญา ในกรณีพิพาทที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ นโยบายสาธารณะของประเทศชาติ

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้เกี่ยวกับกลไกในการยุติข้อพิพาทโดยสันติวิธีแบบต่างๆ โดยเฉพาะการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ และการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพันธกิจระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลง สนธิสัญญาระหว่างประเทศ เกี่ยวกับข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการ กับกฎหมายภายใน และวิธีการในการแก้ไขปัญหา นักศึกษาควรศึกษาหาความรู้ทั้งจากเอกสารการสอน และ ศึกษา วิเคราะห์จากเหตุการณ์ต่างๆทางปฏิบัติ ศึกษาข่าวสาร และ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประชาคมระหว่างประเทศประกอบการศึกษาดูเพื่อฝึกฝนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วย

ข้อ 3. นายเอกคนสัญชาติไทยตกลงขายผ้าไหมโดยทำสัญญาที่ประเทศไทย จำนวน 500 พับเพื่อส่งไปขายยังประเทศอังกฤษให้แก่นายเดวิด ในขณะที่ผ้าไหมดังกล่าวกำลังถูกส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ ได้มีการร้องขออายัดสินค้าดังกล่าวโดยนายเจตน์ ซึ่งอ้างว่าผ้าไหมดังกล่าวนายเจตน์เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แต่นางจูนน้องสาวนายเจตน์ได้ขายให้นายเอกโดยไม่ได้ขออนุมัติจากนายเจตน์ เมื่อสินค้าเดินทางถึงประเทศอังกฤษ นายเดวิด ขอรับสินค้าจากท่าเรือ แต่สินค้าถูกอายัด โดยนายเจตน์ นายเดวิดอ้างว่าตนซื้อสินค้าโดยชอบจากนายเอก

และไม่ทราบเรื่องพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของนายเจตน์ นายเจตน์จึงฟ้องนายเอกและนายเดวิด ที่ศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้ส่งสินค้ากลับมายังประเทศไทยในกรณีนี้ ศาลจะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับกับคดี และ ใครจะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพิพาทนี้

คำตอบ

หลักกฎหมาย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพุทธศักราช 2481

มาตรา 13 ปัญหาว่าจะพึงใช้กฎหมายใดบังคับสำหรับสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ หรือผลแห่งสัญญานั้นให้วินิจฉัยตามเจตนาของคู่กรณี ในกรณีที่ไม่อาจหยั่งทราบเจตนาชัดแจ้งหรือโดยปริยายได้ ถ้าคู่สัญญา มีสัญชาติอันเดียวกัน กฎหมายที่จะใช้บังคับ ก็ได้แก่กฎหมายสัญชาติอันร่วมกันแห่งคู่สัญญา ถ้าคู่สัญญาไม่มีสัญชาติอันเดียวกันก็ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญานั้นได้ทำขึ้น

มาตรา 16 ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์สินตั้งอยู่บังคับแก่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ในกรณีการส่งสังหาริมทรัพย์ออกนอกประเทศ ให้ใช้กฎหมายสัญชาติของเจ้าของทรัพย์สินบังคับแก่ทรัพย์สินนั้นตั้งแต่เวลาส่งทรัพย์สินออกนอกประเทศ

มาตรา 17 สังหาริมทรัพย์ใดๆ ซึ่งได้ย้ายที่ไปในระหว่างฟ้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ให้คงบังคับตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในขณะยื่นฟ้อง

ในการส่งทรัพย์สินออกนอกประเทศ จุดเกาะเกี่ยวมีการเคลื่อนไหว หมายความว่าทรัพย์สินจะเปลี่ยนสถานที่ตั้งอยู่เสมอ ดังนั้น กฎหมายจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดจุดเกาะเกี่ยวที่แน่นอน ซึ่งได้แก่กฎหมายสัญชาติของเจ้าของทรัพย์สิน ขณะสังหาริมทรัพย์ออกนอกประเทศ โดย มาตรา 16 วรรคสอง ระบุว่า “อย่างไรก็ดีในกรณีการส่งสังหาริมทรัพย์ออกนอกประเทศ ให้ใช้กฎหมายสัญชาติของเจ้าของทรัพย์สินบังคับแก่ทรัพย์สินนั้นตั้งแต่เวลาส่งทรัพย์สินออกนอกประเทศ” ปัญหาที่น่าพิจารณาก็คือว่า หากมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในประเทศหนึ่งต่อมาภายหลังทรัพย์สินได้เคลื่อนที่ไปยังอีกประเทศหนึ่งภายหลังการฟ้องคดีนั้น หมายความว่ามีการเคลื่อนไหวของจุดเกาะเกี่ยว กฎหมายจำเป็นจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะถือเอาจุดเกาะเกี่ยวที่ทรัพย์สินเกาะเกี่ยวอยู่ในขณะใด ขณะที่ฟ้องคดีหรือในขณะที่ทรัพย์สินได้เกาะเกี่ยวอยู่ภายหลังได้ฟ้องคดีแล้ว มาตรา 17 ได้แก้ไขปัญหาการขัดกันแห่งการเคลื่อนไหวของจุดเกาะเกี่ยวเอาไว้โดยให้ถือเอากฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในขณะยื่นฟ้อง โดย มาตรา 17 ได้ระบุว่า “สังหาริมทรัพย์ใดๆ ซึ่งได้ย้ายที่ไปในระหว่างฟ้องคดี เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นให้คงบังคับตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในขณะยื่นฟ้อง”

ส่วนอสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องนำเอากฎหมายของประเทศที่ทรัพย์สินตั้งอยู่มาใช้ ปัญหาในเรื่องสังหาริมทรัพย์จะมีความยุ่งยากมาก เพราะกฎหมายภายในแต่ละประเทศบัญญัติเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

แตกต่างกัน หากกฎหมายสองประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นจุดเกาะเกี่ยว กฎหมายที่จะใช้วินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนเมื่อส่งมอบหรือโอนเมื่อทำสัญญาซื้อขายกัน ได้แก่ กฎหมายที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์

มาตรา 1361 เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จะจำหน่ายส่วนของตนหรือ จำนอง หรือก่อให้เกิดการติดพันก็ได้ แต่ตัวทรัพย์สินนั้นจะจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดการติดพันได้ **ก็แต่ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน** ถ้าเจ้าของรวมคนใดจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดการติดพัน ทรัพย์สินโดยมิได้รับความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน แต่ภายหลังเจ้าของ รวมคนนั้นได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่ผู้เดียวไซ้ร้ ท่านว่านิติกรรมนั้นเป็นอันสมบูรณ์

มาตรา 1359 เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ ครอบไปถึงทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อต่อสู้นักบุคคลภายนอก แต่ในการเรียกร้องเอา ทรัพย์สินคืนนั้น ท่านว่าต้องอยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 302 แห่งประมวลกฎหมายนี้

มาตรา 1336 ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย และจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิ ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และ มีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วย กฎหมาย

มาตรา 475 หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อ ในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือ ทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดี เพราะความผิดของ ผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะต้องรับผิดชอบอันนั้น

วินิจฉัย

ประเด็นปัญหา

1. ผ้าไหมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด
2. เป็นกรณีทรัพย์สินเคลื่อนที่ไปแล้วก่อนการฟ้อง หรือ เป็นกรณีที่มีการฟ้องแล้วทรัพย์สินจึงเคลื่อนที่ไป

ในกรณีนี้นางจูนได้ขายผ้าไหมที่มีข้อพิพาทว่ากรรมสิทธิ์ในผ้าไหมเป็นของใคร โดยนายเจตน์โต้แย้งว่าผ้าไหมนั้นมีกรรมสิทธิ์รวมของนายเจตน์และนางจูนแต่นางจูนกลับขายผ้าไหมไปโดยไม่ได้ออกกล่าวต่อนายเจตน์ นางจูนจึงไม่มีสิทธิขายผ้าไหมแต่เพียงผู้เดียว ทรัพย์สินที่ขายไปนั้นจึงยังพิพาทกันด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอยู่ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง พาณิชย มาตรา 1361เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ จะจำหน่ายส่วนของตนหรือ จำนอง หรือก่อให้เกิดการติดพันก็ได้ แต่ตัวทรัพย์สินนั้นจะจำหน่าย จำนำ จำนอง หรือก่อให้เกิดการติดพันได้ **ก็แต่ด้วยความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคน** เมื่อนางจูนยังมิได้รับความยินยอมจากนายเจตน์ นางจูนจึงไม่มีสิทธิขายผ้าไหมแก่นายเอก

และผ้าไหมพิพาทดังกล่าวกำลังถูกส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ ในขณะนั้นได้มีการฟ้องร้องขอให้อายัดสินค้าดังกล่าวโดยนายเจตน์ ซึ่งอ้างว่าผ้าไหมดังกล่าวนายเจตน์เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย จึงต้องพิสูจน์ว่ากรรมสิทธิ์ในผ้าไหมเป็นของใครเสียก่อน ซึ่งคู่พิพาท คือ นายเจตน์ และ นางจูน ซึ่งทั้งคู่เป็นคนสัญชาติไทยและอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยแต่เพียงประเทศเดียว ข้อพิพาทในกรณีนี้จึงเป็นข้อพิพาทที่ไม่มีองค์ประกอบต่างชาติ ซึ่งต้องใช้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่บังคับกับคดีตามมาตรา 1361 ดังกล่าวข้างต้น กรรมสิทธิ์ในผ้าไหมจึงเป็นของนายเจตน์และนางจูนร่วมกันอยู่

ประเด็นต่อมาเกิดประเด็นพิพาทว่านายเดวิดซึ่งซื้อผ้าไหมมาจากนายเอกโดยไม่ทราบว่าเป็นผ้าไหมนั้นจำหน่ายแก่นายเอกโดยมิชอบ จึงพิพาทกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินระหว่างนายเดวิดผู้ซื้อทรัพย์สิน และ นายเจตน์ผู้เป็นเจ้าของรวมและมีกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สิน ในกรณีนี้ แดนกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินของนายเจตน์ซึ่งสามารถกล่าวอ้างได้กับทุกคนในโลก แต่มีกรณีพิพาทกับคนซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐจึงเป็นข้อพิพาทที่มีองค์ประกอบต่างชาติ ในกรณีนี้จึงต้องใช้พระราชบัญญัติกฎหมายขัดกันมาเป็นเครื่องมือในการหากฎหมายซึ่งมาตรา 17 สंहาริมทรัพย์สินใดๆ ซึ่งได้ย้ายที่ไปในระหว่างฟ้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ให้คงบังคับตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในขณะยื่นฟ้อง กล่าวคือฟ้องขออายัดทรัพย์สินในขณะที่กำลังส่งผ้าไหมไปยังประเทศอังกฤษ จึงต้องใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ขณะฟ้องคือกฎหมายของประเทศไทย

ต่อมานายเจตน์ได้ฟ้องนายเอกและนายเดวิดเพื่อขอให้ส่งผ้าไหมกลับสู่ประเทศไทย ในกรณีนี้ มาตรา 16 ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์สินตั้งอยู่บังคับแก่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีการส่งสังหาริมทรัพย์ออกนอกประเทศ ให้ใช้กฎหมายสัญชาติของเจ้าของทรัพย์สินบังคับแก่ทรัพย์สินนั้นตั้งแต่เวลาส่งทรัพย์สินออกนอกประเทศ ดังนั้นในกรณีนี้ต้องใช้กฎหมายสัญชาติเจ้าของทรัพย์สิน คือ นายเจตน์ และนางจูนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมเมื่อทรัพย์สินได้ถูกส่งออกนอกประเทศแล้ว กฎหมายสัญชาติของนายเจตน์และนางจูนคือ กฎหมายไทย ซึ่งตามกฎหมายไทยมาตรา 1361 ดังกล่าวบัญญัติให้การซื้อขายทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวม คือ นายเจตน์ด้วย ดังนั้นเมื่อไม่ได้รับความยินยอมจากนายเจตน์ การซื้อขายทรัพย์สินนี้จึงไม่ชอบ นายเอกไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะนำไปขายให้แก่บุคคลอื่น

ส่วนความเสียหายของนายเดวิดภายใต้สัญญาซื้อขายระหว่างนายเอกกับเดวิดในการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนั้นต้องพิจารณาระหว่างนายเอกกับเดวิดซึ่งตาม พรบ ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายว่าด้วยหนี้อันมีมูลฐานจากมูลสัญญานั้น จะพึงใช้กฎหมายใดบังคับสำหรับสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญ หรือผลแห่งสัญญานั้นให้วินิจฉัยตามเจตนาของคู่กรณี ในกรณีที่ไม้อาจหยั่งทราบเจตนาชัดแจ้งหรือโดยปริยายได้ ถ้าคู่สัญญามีสัญชาติอันเดียวกัน กฎหมายที่จะใช้บังคับ ก็ได้แก่กฎหมายสัญชาติอันร่วมกันแห่งคู่สัญญา ถ้าคู่สัญญาไม่มีสัญชาติอันเดียวกันก็ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญานั้นได้ทำขึ้น สัญญาการซื้อขายนี้ทำขึ้นที่ประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องใช้กฎหมายไทยบังคับกับคดี เนื่องจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้ตกลงเลือกที่จะใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับกับคดี คู่สัญญาไม่ได้มีสัญชาติเดียวกัน จึงต้องใช้กฎหมายของประเทศที่มีการทำสัญญาเกิดขึ้น ซึ่งตาม

กฎหมายไทยผู้ขายต้องรับผิดชอบในการรอนสิทธิต่อผู้ซื้อ ดังนั้น นายเอกต้องรับผิดชอบต่อนายเดวิดเองตามสัญญาซื้อขาย แต่จะไปเรียกร้องจากนายเจตน์ และ นางจูนไม่ได้

สรุป

ในคดีนี้ศาลจะต้องใช้กฎหมายของประเทศไทยบังคับกับคดี และ นายเจตน์และนางจูนยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินพิพาทนี้ และนายเอกต้องรับผิดชอบต่อนายเดวิด ตามกฎหมายไทย

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการปรับกฎหมายกับข้อเท็จจริง และการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย อันเป็นเครื่องมือในการหากฎหมายมาบังคับกับคดีได้อย่างถูกต้อง และสามารถวิเคราะห์ ข้อพิพาทที่มีองค์ประกอบต่างชาติได้ นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องอ่านทำความเข้าใจในเอกสารการสอน การคิด และ วิเคราะห์ กฎหมาย การปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง นักศึกษาก็จะสามารถสอบผ่านได้

